

給臺灣制憲的備忘錄^{*}

—— 以程序面為中心

林建志^{**}

摘要

臺灣要制定憲法將面臨相當風險與成本，不但對內容容易激化政治對抗，對外造成國際局勢緊張，而且現行中華民國憲法並未規範如何制定新憲法，這些情況都可能造成制憲失敗，甚至使得在民主時期開啟的憲政工程，反而會導致憲政秩序的崩壞。為了避免這些狀況，本文首先指出有三種可能的制憲途徑：事前不予規範、沿用修憲程序、以及簽署政黨備忘錄。就細節而言，本文結合比較憲法上的研究，以及中華民國過去的制憲經驗，主張在臺灣制定新憲法之前，有必要先仔細討論制憲的程序要件。這麼做有兩個好處，一是可以讓將來真正要制定新憲法時，有規則可以遵循，不至於手足無措或流於民粹；二來是可以透過程序設計，創造憲法政治上的無知之幕，而使得新憲法的內容更不容易為短期的政黨利益所綁架。

關鍵詞：中華民國憲法、制憲、憲法變遷、公民投票、民眾參與。

* 投稿日：2022年3月25日；接受刊登日：2022年7月6日。〔責任校對：李友銓〕。

本文受科技部計畫（MOST 109-2410-H-001-033-MY2）之補助。作者感謝審查人的諸多評論與意見。本文初稿曾於中央研究院法律學研究所午餐聚會（Bento Box Meeting）中報告，作者感謝所有與會者的討論，並特別感謝蘇彥圖、黃丞儀、與宋承恩，在本文修改過程中的建議，惟文責當自負。最後感謝林田凱與方俞尹的研究協助與校對。

** 中央研究院法律學研究所研究員、國立臺灣大學國家發展研究所合聘副教授。
穩定網址：<https://publication.iias.sinica.edu.tw/70514032.pdf>。



目次

壹、前言	二、憲法草案產生機關
貳、臺灣需要新憲法嗎？	三、制憲委員會的人數、組成、與討論時間
一、憲法缺陷與憲法認同的轉變	四、制憲原則
二、其他憲法變遷管道的不足	五、制憲工程與司法審查
三、制憲的三種途徑	肆、公眾參與
參、制憲程序	伍、結論
一、行使制憲權主體	

壹、前言

「永矢咸遵」是中華民國憲法前言的最後四個字，代表當年在南京的制憲者希望中華民國憲法能夠被後代永遠的遵守。這其實有兩個面向，第一個是中華民國憲法能夠長久下去不要被取代，第二個則是這部憲法會被自動地遵守。兩者在實踐上高度重疊，但不必然如此，在過去，中華民國憲法有相當多條文被動員戡亂時期臨時條款暫停適用，但形式上並未被廢止，即足以說明這兩個面向之間的差異。然而在1940年代，制憲者並不知道如何制定一部既長久（enduring）又會被自動遵守（self-enforcing）的憲法。到了70多年後的今天，物換星移，在臺灣，不論朝野，要求制定新憲法的聲音一直不絕於耳。例如在解嚴後不久，李登輝前總統召開的國是會議上，便已經論及制憲與修憲的可行性¹；此外，張榮發基金會成立的國家政策研究資料中心，在1990年就已經委託法政學者，草擬提出中華民國憲法改革案。其雖名為改革案，但觀其說明與草案內

¹ 國是會議實錄編輯小組編，國是會議實錄（上輯），頁789-941（1990年）。

容，實質上已經是一部新憲法草案²。這股要求制憲的聲浪並未消失，在2020年5月，有14個社會團體聯合提出制定新憲法的訴求，其理由約略為中華民國憲法並未真實呈現臺灣的國家四要素，更甚至導致國家認同與國際地位的問題³；同年4月，臺灣制憲基金會亦曾試圖提出公投案要求制憲，惟遭中選會駁回⁴，其理由據報載略為不符合重大政策之創制、且公投案主文內容不易理解⁵；此外，由李前總統與黃昭堂先生所成立的台灣國家聯盟，也一直以制定新憲為其目標。針對這個議題，憲法學界在討論是否制憲、以及如何制憲此一議題時，除了回顧臺灣制憲運動的歷史⁶、抽象地討論制憲權此一概念⁷之外，還及於憲改的程序應如何進行⁸。最後，現行的中華民國憲法是臺灣目前最高位階的法規範，在臺施行也逾70年，儘管學者對憲法文本有諸多批評⁹，但倘若臺灣將來真的需要

-
- 2 財團法人張榮發基金會國家政策研究資料中心編，共識：中華民國憲法改革案，頁7-56（1990年）。
 - 3 連署新憲聲明，聲明本文，經濟民主連合網站，<https://sites.google.com/view/making-our-own-constitution/%E8%81%B2%E6%98%8E%E9%80%A3%E7%BD%B2?authuser=1>（最後瀏覽日：2022年1月15日）。
 - 4 中選會委員會會議審議5項全國性公民投票提案，中央選舉委員會，2020年10月16日，<https://www.cec.gov.tw/central/cms/109news/34268>（最後瀏覽日：2022年1月15日）。
 - 5 賴佩璇，獨派大老提制憲意向公投遭駁回 告中選會並求聲請釋憲，聯合新聞網，2022年12月14日，https://udn.com/news/story/7321/5090909?from=udn-catebreaknews_ch2（最後瀏覽日：2022年1月15日）。相關討論參林佳和，憲法政策不得公投？從公投法第2條第2項第3款談起，台灣法學雜誌，410期，頁65-84（2021年）。
 - 6 曾建元，台灣制憲與中國制憲——啟蒙與歷史的辯證，台灣國際研究季刊，15卷3期，頁141-169（2019年）；曾建元，臺灣制憲運動的回顧與展望——以民主進步黨為中心，法制史研究，25期，頁131-161（2014年）。
 - 7 蔡宗珍，從制憲力之法理論憲法之制訂與修改，法政學報，7期，頁109-133（1997年）；陳慈陽，制憲與修憲之區分及憲改之必要性，新世紀智庫論壇，35期，頁59-64（2006年）。
 - 8 例如李建良，面對中華民國憲法——思索台灣憲改之路，收於：湯德宗、廖福特編，憲法解釋之理論與實務（五），頁55-98（2007年）；張文貞，憲政改造的方式與程序，收於：行政院研究發展考核委員會編，憲改方向盤，頁16-54（2006年）。
 - 9 例如林子儀等，憲法：權力分立，頁627-643（2003年）。

制憲，中華民國過去制憲的經驗，或許可以作為參考。在這些基礎之上，本文試圖透過兩個角度來分析臺灣未來應當如何制憲這個重要的議題¹⁰。

第一個角度是從理論的角度，也就是透過目前比較憲法學界，觀察世界各國制憲經驗後所提出的研究，來分析臺灣的情形。憲法制定（constitution-making）在國際比較憲法學界，是一個相當熱門的議題。這有許多理由，但其中最直接的一個原因就是制定憲法這件事情，其實遠比多數人想像中來得頻繁，因此具有高度研究價值。實證研究顯示，世界各國的憲法，其「壽命」的中位數約僅為短短的19年¹¹。究竟這麼多的新憲法是如何被制定？被誰制定？而憲法制定的過程中，又是受到什麼因素的影響？制定後實踐的情況如何？成敗是否起因於制定的過程？這些問題的答案與憲法制定的過程，又隨著各地的政治社會脈絡，而有高度的歧異性，如何透過這些言人人殊的制憲經驗，制定一部好的憲法，便具有相當的學術與實務價值，因為憲法不但在象徵意義與規範意義上，都是一個國家的根本大法。在這個前提之上，憲法設計的良莠，會在相當程度上影響一國政治局勢的穩定，如何效仿他國制憲成功的經驗，避免重蹈他國制憲失敗的覆轍，對臺灣將來制憲乃至未來的憲政發展，都是重要的課題。這麼做並不是預設了他國的憲政設計移植到臺灣來可以發揮同樣的功效，事實上也不可能¹²，而是為了避免盲人摸象，閉門造車¹³。

10 所謂憲法，有許多涵義，參林子儀等（註9），頁3-4。本文所指涉者，乃是形式意義的成文憲法，也就是被命名為憲法、且在規範效力上具有最高權威的法律文件，在臺灣的脈絡下，就是指中華民國憲法以及中華民國憲法增修條文，而不是指其他實質意義或現代意義的憲法。也就是說，本文所稱制憲，都是在形式意義的憲法的層次上進行討論。

11 ZACHARY ELKINS ET AL., THE ENDURANCE OF NATIONAL CONSTITUTIONS 129 (2009).

12 Donald L. Horowitz, *Constitutional Design: Proposals versus Processes*, in THE ARCHITECTURE OF DEMOCRACY: CONSTITUTIONAL DESIGN, CONFLICT MANAGEMENT, AND DEMOCRACY 15, 36 (Andrew Reynolds ed., 2002).

13 在方法論上要進一步考量的問題是：是否應該只討論那些與臺灣同為民主轉型

第二個角度則是從中華民國過去的經驗，也就是從中華民國憲法制定的歷史中吸取教訓¹⁴。既有的研究指出，制憲過程的選擇，往往同時受到過去憲政體制的表現與制憲當下的政黨利益所決定¹⁵。如同子女通常會受到家庭的影響，一國憲法的制定與穩定性，不論是出於巧合或路徑依賴，相當程度上會受到該國過去憲法制定經驗的影響¹⁶。而中華民國憲法的制定過程，相當漫長且曲折，且制定過程中的疏失，確實造成了往後臺灣憲政發展的困擾，也促成了幾號司法院大法官解釋的誕生，這中間固然有部分是因為中華民國經歷國共內戰的關係，導致中華民國憲法在臺灣施行上有窒礙難行之處，但中華民國憲法在設計上，本身確實也有它的問題。

換句話說，唯有將過去制憲的經驗去蕪存菁，以理論配合臺灣的脈絡做適度的調整，才可能制定出一部好的憲法。由於臺灣目前並沒有關於制定新憲法的法規範依據，因此本文主要是從比較憲法的國際經驗，輔以中華民國憲法的制定過程，來探討我國未來的制憲程序，究竟應該採取哪一種模式，以及其他程序要求，其目的在於設計一套制憲的制度，以供臺灣未來制憲時參考之用。本文結構

後數十年才制定新憲法的國家？就這點而言，理論上雖然不無道理，但實際上由於牽涉制憲成功與否的變項太多，民主鞏固與否固然重要，但其他因素，像是社會經濟發展程度、國際環境、宗教傳統……等等，都可能影響制憲成敗，因此難以僅憑民主轉型的發展此單一變項，排除其他國家的制憲經驗，因為我們不知道民主轉型是否為影響制憲成敗的重要因素。反過來說，臺灣與其他國家在制憲這議題上最大的不同，可能在於臺灣獨特的國家定位與中國因素，就這點而言，似乎也難以找到與臺灣相似的國家。此外，每個國家制憲的起始條件不同之外，制憲的目的也不盡相同，這雖然不代表著其他國家的經驗就完全不可參考，但這意味著不可能特定出任何制憲路徑或程序設計，可以作為臺灣制憲的完美解方，而必須在諸多國家的經驗間截長補短。See DONALD L. HOROWITZ, CONSTITUTIONAL PROCESSES AND DEMOCRATIC COMMITMENT 66-67 (2021).

14 李仁淼，自制憲權之觀點思考我國憲政改革之問題點，月旦法學教室，144期，頁42-53（2014年）。

15 GABRIEL L. NEGRETTO, MAKING CONSTITUTIONS: PRESIDENTS, PARTIES, AND INSTITUTIONAL CHOICE IN LATIN AMERICA 14 (2013).

16 ELKINS ET AL., *supra* note 11, at 145.

安排如下，除了前言之外，第「貳」節將扼要討論臺灣目前究竟有無重新制憲的必要，以及制憲的三種途徑。對內而言，由於制憲是成本相當高的政治行為，光是提案制憲，都將造成內部政治紛爭，因此必須謹慎為之。此外，在高度全球化的今日，憲法變遷與否已經不只是單純一國主權的展現而已，而必須考量諸多地緣政治與國際因素（例如日本憲法第9條關於和平憲法的爭議），外在的環境是否會造成制憲額外的成本，也是一個不得不考慮的因素。第「參」節將探討如果臺灣將來需要制定一部新憲法，則所應遵循的原則為何？棘手的是，這些原則彼此之間，往往有所衝突，而需要彼此妥協，如何執兩用中，都需要審慎思辨。此外，憲法草案文本出爐後，給一般民眾的審閱期間長短、是否需要經過司法審查、以及批准的門檻，都會在此一併討論。第「肆」節則分析人民在制憲過程扮演的角色。最後第「伍」節則是結論。

本文初步認為制定一部新憲法對於臺灣固然有所幫助，但短期內並沒有迫切的需要。不過，正因為沒有急迫性，目前反而是一個臺灣人民理性思考將來該如何制定憲法的最佳時機，以免將來制憲迫在眉睫時，反而受到一時群情激昂或政黨利益的影響，而制定出一部糟糕的憲法，不利於臺灣長遠的憲政發展。因此，本文建議臺灣應當仔細討論往後制定憲法的程序事項，在修憲和憲法法庭裁判之外，創設第三種憲法變遷途徑。應強調的是，這不影響上述兩種憲法變遷管道繼續存在，即使本文的主張成立，充其量僅是多種憲法變遷管道並立。由於在規範層面上，得制憲、得修憲、與得釋憲的內容或標的均未必相同，而在實踐層面上，這些不同憲法變遷管道的政治和社會經濟成本也相差甚遠，因此這些憲法變遷管道並不一定彼此衝突。最後，本文將聚焦於程序面向的要求，至於新憲法的實質內容，例如該採總統制或內閣制、或權利清單中應納入哪些社會經濟文化權利，政治學界與法學界已有諸多研究，礙於篇幅限制，便不在本文主要討論的範圍之內。

貳、臺灣需要新憲法嗎？

制定一部新憲法是一個浩大且艱鉅的工程，不論是因為路徑依賴，或是少數既得利益者的阻撓，即使全民都有共識，仍然需要耗費極大的政治與社會能量。更何況臺灣自從民主轉型以來，基於不同的國族想像與國家認同，社會對立日趨壁壘分明，兩大黨除了極少數有共識的議題，像是降低投票年齡之外，其他議題均不免形成政治僵局。在這種情況下，是否要推動制定新憲法，自然必須考量諸多因素，包括既有的憲法有何缺陷？這些缺陷是否無法透過既有的憲法變遷管道進行彌補？臺灣人民的憲法認同是否已經變更？制定一部新的憲法是否真的如此重要？比較憲法學界在判斷一部憲法成功與否時，常以憲法本身的延續年限、一國的人權指標，或是人類發展指標作為判斷標準¹⁷，以這些標準來說，中華民國憲法在形式上堪稱是一部成功的憲法，蓋其不但已歷經70餘年未被取代，且臺灣不論在人權指標或人類發展指數上，在國際間都名列前茅。當然，一部憲法「成功」與否，判斷標準為何本身是一個頗富爭議的問題，也不是本文要深究的爭議，這裡充其量只是點出，以一些常見的標準來說，現行中華民國憲法，在歷經七次修憲與諸多大法官釋憲之後，實務運作上並不是一部非常糟糕的憲法，臺灣人民之所以希望重新制憲，有憲法品質本身以外的原因。

一、憲法缺陷與憲法認同的轉變

一部憲法不論在制定當時如何完美，隨著時代流轉，科技與社會的發展，以及對於民主、正義、或平等這些概念在理解上的改變，都必然會產生憲法規範與現實不符，甚至是違反民主之處¹⁸。

¹⁷ See ELKINS ET AL., *supra* note 11.

¹⁸ See SANFORD LEVINSON, OUR UNDEMOCRATIC CONSTITUTION: WHERE THE CONSTITUTION GOES WRONG (AND HOW WE THE PEOPLE CAN CORRECT IT) *passim* (2006).

這是所有制憲者所不可避免的智識上的侷限，也因此才會有各種憲法變遷的途徑，試圖縮小文本與現實的差距，以延長一部憲法的壽命。在這點上，中華民國憲法雖然不如一些施行已長達兩個世紀的憲法（像是挪威王國憲法），但迄今也已經逾70年。即使不論時間因素，中華民國在經歷國共內戰後，不論政社經條件、甚至領土疆域均早已有劇烈改變，在這種狀況下，憲法規範與臺灣現況有所落差，自不讓人意外。早在上個世紀末，臺灣開啟憲政改革工程時，學者便提出所謂「龍的憲法」¹⁹，意指著中華民國憲法乃是基於許多自相矛盾、彼此扞格的概念、學理、甚至是主義所拼湊產生，正如龍的形象乃是由各種生物所組合而成。由於這種大雜燴的拼湊方式，因此憲法本身便具有許多窒礙難行之處。

這些缺失雖然部分已經在修憲過程中解決，但修憲本身同樣是高度政治性的行為，在解決既有問題的時候，也可能因為權力鬥爭與人謀不臧，產生新的問題。最好的例子就是中華民國憲法增修條文的前言與本文，自1991年第一次修憲以來，除了增列「因應國家統一前之需要」之外，並區分「中華民國自由地區與大陸地區」。換句話說，似乎以一個中（華民）國為原則²⁰——不論這裡指的中（華民）國是當今的，或是未來的中（華民）國——並預設了臺灣必須與對岸的中國（亦即所謂大陸地區）統一的憲法政策，這個政策是否、以及在什麼程度上有拘束力，容有許多不同看法。有認為因應統一前之需要，是一種目標，但沒有時程表或條件²¹；也有認為這並不代表兩岸一定要統一，因此憲法前言頂多只能算是一種「對於未來國家走向的政策聲明（甚至也未必成立軟性的憲法義

19 李鴻禧，李鴻禧憲法教室，頁197-218（1994年）。

20 蘇永欽，尋找共和國，頁5-9（2008年）；不同看法，請參見許宗力，兩岸關係的法律定位——臺灣的角度出發，收於：黃昭元編，兩國論與台灣國家定位，頁148-150（2000年）。

21 林恩如，馬：統一是目標！要有適當條件和時機，三立新聞網，2018年12月20日，<https://tw.news.yahoo.com/馬-統-是目標-要有適當條件和時機-045513404.html>（最後瀏覽日：2023年4月1日）。

務)」²²；但也有認為「該『統一前』一詞似可解為憲法本身對統一目標的揭櫫，準此，追求與對岸的合併，將可構成在台灣的中華民國舉國上下的憲法義務。²³」當然，也有認為這些文字只能算是一種政治權宜之計，雖然保留了統一的可能性，但也未必排除獨立的選項²⁴。不論其拘束力如何，在今日已經淪為中國政府在國際上用來宣傳一個中國原則的說詞：即使是臺灣的憲法也贊成一個中國²⁵。更重要的是，這項期待或政策在今日已經背離臺灣主流民意，根據政治大學選舉研究中心研究²⁶指出，截至2022年12月，臺灣民眾認同自己只是臺灣人的比例已經超過60%，而剩下不到四成民眾中，除了有33%的民眾認為自己既是臺灣人也是中國人之外，只有3%的民眾認同自己只是中國人。更重要的是，由於這調查已經持續長達20年，其趨勢顯示這種國家認同的轉移，是很明顯且不可逆的。從這個角度來看，上述憲法規範的民主正當性，在今日便不能無疑。

換句話說，中華民國的國家同一性已經發生改變，如今的中華民國，不論在領土、人民、或是主權範圍上，都已經不再是1912年推翻清帝國的那個中華民國，這是很清楚的。至於「中華民國憲法」這部憲法的同一性，雖然其名稱不變，但憲法同一性（constitutional identity）已經產生質變。過去的中華民國憲法本文，體現的是一種以三民主義、五權憲法為基礎的大中國憲政秩序，這從其前言、憲法第1條、政府組織、乃至對於邊疆地區與地方自治的規範即可自

22 黃昭元，兩國論的憲法分析——憲法解釋的挑戰與突破，收於：黃昭元編，兩國論與台灣國家定位，頁26（2000年）。

23 許宗力（註20），頁154。許同時認為這種憲法目標，在憲法政策上頗有商榷之餘地，因其可能違反人民意願。

24 作者感謝審查人提出此一可能性。

25 William Lowther, *China Touts Taiwan Constitution*, TAIPEI TIMES (Feb. 27, 2016), <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/02/27/2003640311>.

26 政治大學選舉研究中心，臺灣民眾臺灣人／中國人認同趨勢分佈（1992年06月～2022年12月），<https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7804&id=6960>（最後瀏覽日：2023年5月12日）。

明。而司法院釋字第31號解釋，一方面是這種大中國憲法認同的產物，另一方面也在國民黨政府遷臺後，重新宣示並鞏固了這種憲政秩序。這並不令人意外，蓋中華民國憲法本來就是為了在1947年統治權尚及於中國大陸的中華民國所制定。然而隨著國民政府遷臺，歷經多次正式或非正式的憲法變遷之後，中華民國雖然名稱並未改變，但整體的憲政秩序已經大有所不同，例如劃時代的司法院釋字第261號解釋終結了萬年國會，從此這個國家的代表將由（也僅由）臺灣人民選出；此外，省政府與蒙藏委員會的裁撤，進一步動搖了中華民國憲法下的大中國憲政框架。甚至前總統李登輝在接受德國之聲訪問時，主張在1990年代修憲後，兩岸已經處於一種（特殊）國與國的關係，作為一國的元首，這種宣告本身都具有憲法認同轉向的意涵。更白話地說，即使憲法修正條文區分自由地區與大陸地區，也沒有臺灣人會認為習近平是中華民國的國民。這些都具體而微的顯示了憲法認同的改變。這也就是學者所主張的，現行中華民國憲法已經與1947年在中國大陸公布、實施的中華民國憲法相距甚遠。隨著臺灣民主化、經歷七次修憲，甚至是多年的大法官解釋之後，現行憲法不論在水平或垂直的權力分立結構上、甚或是基本權利的保障內容，都與當年制憲者的想像大相逕庭，也就是「臺灣化」了²⁷。這當然不是說整部中華民國憲法已經全然臺灣化，由上述憲法增修條文與前言均可看出「一中憲法」的幽靈仍然盤旋在臺灣上空，但這些改變確實顯示了臺灣人的憲法認同，隨著國家認同一樣，逐漸在改變當中，也因此，進行憲法改革對臺灣人來說確實有其實益，接下來的問題是：是否必須採取重新制憲這種最激進的手段，還是可以仰賴其他憲法變遷的管道？

27 王泰升，臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，頁133（2015年）；JIUNN-RONG YEH, THE CONSTITUTION OF TAIWAN: A CONTEXTUAL ANALYSIS 24（2016）。

二、其他憲法變遷管道的不足

縱使我們認為既有的憲法確實需要調整，但重新制憲也非理論上唯一的解決方法，制度上有其他以較小成本促進憲法變遷的方式以資補救，包括正式或非正式的管道，前者像是繼續啟動修憲程序，以矯正憲法與現實脫節、甚至相牴觸之處，這也是修憲程序最大的功能之一，在於使代代人民在這個意義上都能擁有屬於他們的憲法，同時得以避免為了制定一部新憲法所造成的政治動盪與社會成本²⁸。而後者則又可分為兩種，一種是透過法院的憲法解釋，重新賦予憲法文本新的時代意涵；另一種則是透過政治部門長久以來的政治慣習，以達到實質上建立另一種憲政慣例或毀棄特定憲法規範（constitutional desuetude）²⁹的效果。從上述中華民國憲法「臺灣化」的論述來看，這些較溫和的憲法變遷方式，確實有發揮相當的功能。

然而，這些憲法變遷方式，可能都無法彌補上述中華民國憲法與臺灣社會脫節的情形，也就是要求統一的憲法政策。這使得重新制憲似乎是無法迴避的選項。詳言之，理論上固然可以透過重新修憲將目前涉及「一中憲法」的文字刪除，然而在第七次修憲中，當時的修憲者設立了難以跨越的雙門檻，除了要求立法院要有立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議外，更要有過選舉人總額半數之同意，具體來說要有約970萬人同意方得通過。從一方面來說，這當然可以解釋為因為修憲需要真正凝聚全民共識，因此任何無法獲得共識的議題，即使是社會大多數人的意見，也不應當輕易寫入憲法中。然而從另一方面來

28 SANFORD LEVINSON ED., RESPONDING TO IMPERFECTION: THE THEORY AND PRACTICE OF CONSTITUTIONAL AMENDMENT *passim* (1995); RICHARD ALBERT, CONSTITUTIONAL AMENDMENTS: MAKING, BREAKING, AND CHANGING CONSTITUTIONS 39 (2019).

29 Richard Albert, *Constitutional Amendment by Constitutional Desuetude*, 62 AM. J. COMP. L. 641, 641 (2014); see also David A. Strauss, *The Irrelevance of Constitutional Amendments*, 114 HARV. L. REV. 1457, 1469-75 (2001).

講，這不啻是給少數人以自身的政治偏好凌駕多數人的特權。當然，倘若得以簡單多數決提出或甚至通過修憲案，可能也未必是最妥適的做法，但我們無須從一個極端走向另一個極端，縱使簡單多數決會造成憲政秩序的不穩定，似乎也無須以超高門檻造成憲政秩序的僵化，現行中華民國憲法的超高門檻，使得臺灣針對要求統一的憲法政策，很難有修改的空間。

當然，修憲絕非憲法變遷的唯一途徑，司法院大法官過去也曾多次以解釋促成憲法變遷，然而這些主要都發生於人權保障的領域，像是承認同性婚姻的司法院釋字第748號解釋，或是廢除通姦罪的司法院釋字第791號解釋，都可以合理地推斷已經改變了70年前制憲者對於婚姻與家庭的想像。這主要是因為基本人權的規範通常用語模糊，給予釋憲者較大的空間重新詮釋憲法。但在其他領域，憲法規範用字相對明確，大法官得以透過解釋變更憲法原意的空間就更為限縮了。事實上，礙於司法權的限制，大法官在面對涉及國家認同的議題時，其實是非常謹慎且保守的，以司法院釋字第328號解釋為例，當大法官面臨界定國家領土範圍這種具有國家定位意涵的議題時，其採取政治問題不解釋原則來迴避此一問題。類似的司法自制情況發生在司法院釋字第329號解釋，當面臨何謂憲法上的條約時，大法官先是指出「憲法所稱之條約係指中華民國與其他國家或國際組織所締結之國際書面協定」，但又在理由書中補充「臺灣地區與大陸地區間訂定之協議，因非本解釋所稱之國際書面協定……」，似乎間接承認了憲法一中的架構。從司法政治的角度來看，這無可厚非，畢竟要司法權介入國家定位這種議題風險過大，但造成的結果就是司法解釋無法在這些領域促進憲法變遷。事實上，蘇永欽教授早已指出，憲法法院在人權保障與政府體制這兩個場域的差異：在前者，法院經常可以引領臺灣社會變遷，但在後者，法院往往只能亦步亦趨地跟隨政治部門³⁰。

30 蘇永欽（註20），頁113-115。

最後，透過反覆的政治實踐在實質上造成憲法變遷，同樣不可行，其理由相當簡單，要透過這種方式促成憲法變遷，往往需要主要政黨間都有共識，因此不管政黨如何輪替，兩大黨都會自動地遵守這種約定俗成的方式，以總統與行政院長的互動為例，不論是國民黨或民進黨的總統，都很清楚知道他們與其所任命的行政院長之間，權力關係絕非如憲法所明文規範的那樣。政治現實上，總統才是最高行政首長，而非如憲法第53、54條所指涉的行政院長。但就與中國統一的憲法政策而言，兩大黨顯然不會有共識，舉例來說，馬英九前總統便曾多次公開主張臺灣人民不應反對與中國統一，因為憲法已經如此明定³¹，這種說法的是非容有討論餘地，但就本文而言，重要的是證明了無法透過政治實踐來變更這部分的憲法意旨。

總之，如果我們認為現行的中華民國憲法確實有某些重大缺陷存在，而這些缺陷無法藉由既有的憲法變遷模式獲得改善的話，那麼制定一部新憲法確實有其實益。但有實益不代表沒有成本，制定新憲法堪稱是一國憲法政治中最重要的事情，必然會在極大程度上改變政治議程，轉移政府施政的能量。對內而言，臺灣目前內部的政經局勢穩定發展，國人的國家認同，不論是所謂的統派、華獨、或臺獨，似乎不會因為憲法的更動而有所變化，制定憲法本身反而容易引起政治騷動，進而刺激社會對立³²。對外而言，制定一部新憲法的象徵意義，將必然引起中國的反彈乃至國際情勢的緊張³³，在這種（國際）政治現實下，現在制定一部新憲法，似乎並不是對臺灣憲政發展最有幫助的事。換句話說，制憲的目的在於進一步鞏固、深化臺灣的憲政發展，而不在於象徵性地代表臺灣人民不受中國的控制（畢竟這已經是一個既存的事實），如果制憲無法對臺灣

31 Stacy Hsu, *Ma Defends 'No Opposition to Unification'*, TAIPEI TIMES (Dec. 6, 2018), <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/12/06/2003705598>.

32 張嘉尹，憲政改造的途徑選擇——以台灣憲法變遷為脈絡的思考，收於：葉俊榮、張文貞編，新興民主的憲政改造，頁115-117（2008年）。

33 黃昭元（註22），頁34。

的憲政發展有實質貢獻，甚至還危及臺灣的民主憲政秩序，那麼反而將得不償失。

換個角度來說，這涉及制憲在國家主權建立中扮演怎樣的角色，在臺灣的脈絡下，到底制憲的是中華民國？還是臺灣？還是更模稜兩可的中華民國（臺灣）？然而，不論是哪一個，對於中華民國要重新制憲所面臨的困難，並無太大的不同。如上所述，中華民國雖然國名不變，但國家同一性已經改變，而就憲法同一性而言，在經過諸多修憲條文對於中華民國憲法的「臺灣化」之後，也已經有相當程度的改變，因此如何透過制憲來反映國家同一性的變遷，就涉及制憲與建國（state-building）的關聯。詳言之，許多國家往往在獨立建國的過程中，會制定一部新憲法來彰顯新國家的誕生，這在二戰前多為西方國家殖民地的亞洲更是明顯³⁴。而新憲法和新國家之間的關係，又可以從兩個角度來觀察。首先，新興國家常常具有許多不利於一國長治久安的情況，例如孱弱的國家治理能力（state capacity）、經濟蕭條、以及因不同種族、宗教而產生的社會對立，在這些情況下，制定一部新憲法常常被用來作為凝聚一個政治共同體的手段³⁵。當然，這種手段未必會成功，因為人們可能欠缺對新憲法的認同與對憲政主義的信仰，因此往往會著重透過公眾參與制憲的過程，來強化人民對於新憲法的忠誠，進而接受新憲法所安排的各種制度，並鞏固新興民主。一言以蔽之，新憲法是內國人民為了鞏固新國家所制定。

除了這種內部視角之外，如果從國家和其他國家的角度來看，新國家（或新政權）的建立和新憲法的制定有時候是外國勢力干預

34 H. KUMARASINGHAM ED., CONSTITUTION-MAKING IN ASIA: DECOLONISATION AND STATE-BUILDING IN THE AFTERMATH OF THE BRITISH EMPIRE *passim* (2016).

35 Joanne Wallis, *Constitution Making and State Building*, in COMPARATIVE CONSTITUTION MAKING 278, 278-82 (David Landau & Hanna Lerner eds., 2019); JOANNE WALLIS, CONSTITUTION MAKING DURING STATE BUILDING 2-3 (2014).

的結果，比較憲法理論上經常探討的是被強加的憲法（*imposed constitutions*）與新興國家之間的關係。所謂被強加的憲法，通常意指著作為一國的根本大法，是在外國人監督下、由外國人所「協助」制定、或通過的，而沒有獲得內國人民的充分參與和同意，這通常發生在戰爭結束後，戰勝國對戰敗國的處置³⁶，像是日本憲法、德國基本法、以及伊拉克憲法。除了這種比較明顯的狀況外，聯合國經常在世界各地協助新興國家制定憲法³⁷，這些行為經常會被批評為以（西方）憲政主義之名包裝的新形態帝國主義³⁸，因為在這種情況下，新憲法則是外國勢力為了確保新興國家符合一定的價值觀所制定，而這些價值觀未必為當地人民所接受，因此，由於缺少當地人民的實質參與，新憲法往往（但並非絕對）未能凝聚政治共同體，許多在這種情況下建立的新國家，在建國之後常常還是百廢待舉，例如伊拉克或阿富汗，在這種情況下，新憲法的制定，與其說是在鞏固新國家的建立，有些時候往往反而導致新國家的動盪。

然而，臺灣的狀況則與此不同，不論是認為中華民國要制定第二部憲法，還是認為居住在臺澎金馬上的人民，要建立一個以臺灣（或其他名稱）為名之國家，並制憲表彰之，我國未來要制憲最困難的癥結點，既不在於臺灣人民對憲政主義缺乏信心或經驗，也不

36 Noah Feldman, *Imposed Constitutionalism*, 37 CONN. L. REV. 857, 858-59 (2005); Richard Albert, Xenophon Contiades & Alkmene Fotiadou, *Introduction: Imposition in Making and Changing Constitutions*, in THE LAW AND LEGITIMACY OF IMPOSED CONSTITUTIONS 1, 2 (Richard Albert, Xenophon Contiades & Alkmene Fotiadou eds., 2019); ANDREW ARATO, CONSTITUTION MAKING UNDER OCCUPATION: THE POLITICS OF IMPOSED REVOLUTION IN IRAQ *passim* (2009); Zachary Elkins, Tom Ginsburg & James Melton, *Baghdad, Tokyo, Kabul: Constitution Making in Occupied States*, 49 WM. & MARY L. REV. 1139, 1139 (2008).

37 VIJAYASHRI SRIPATI, CONSTITUTION-MAKING UNDER UN AUSPICES *passim* (2020); Zaid Al-Ali, *Constitutional Drafting and External Influence*, in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 77, 77 (Tom Ginsburg & Rosalind Dixon eds., 2011).

38 James Tully, *The Imperialism of Modern Constitutional Democracy*, in THE PARADOX OF CONSTITUTIONALISM: CONSTITUENT POWER AND CONSTITUTIONAL FORM 315, 315 (Martin Loughlin & Neil Walker eds., 2007).

在於有外國勢力要強加一部憲法在臺灣人民上。真正的困難在於國際政治的現實：縱使臺灣人民對於制憲有共識，制憲不但將面臨中國極力反對甚至導致武裝衝突，美國或其他民主陣營的國家恐怕也不會支持。如何克服這種國際政治的現實，程序上一個可能的做法，或許是模仿其他第三波民主轉型國家的經驗，透過修憲程序，大幅變更現行中華民國憲法的內容，來進行形式上雖然是修憲、但實質上是制憲的憲法變遷（詳如第「貳、三」節所述）。畢竟由過往的經驗看來，臺灣已歷經七次修憲，修改憲法是一個中國與美國都可以接受的情況。這種方法強調制憲與修憲的相對化，但也是因為這種相對化，可能會引起部分主張臺灣應該正名制憲者的反對，進而無法開啟這種透過修憲程序來進行的制憲工程。因此這種刻意模糊修憲與制憲的做法，在臺灣的脈絡下是否真的可行，仍取決於國際政治與國內環境的發展，畢竟這是一個任何比較憲法理論或制憲經驗都難以根本解決的政治問題。

當然，這不代表比較憲法中的憲法設計理論對於臺灣制憲的其他方面沒有幫助，臺灣要制憲除了要面臨中國的威脅之外，內部對於許多重要問題，像是國名、中央政府體制、和國家定位，也還沒有足夠高的共識，因此，如何在憲法設計的過程中，緩和這些歧異對將來所造成的負面影響，是憲法設計理論和制憲經驗可以提供參考的地方。

三、制憲的三種途徑

雖然本文認為臺灣短期內並沒有制定新憲法的急迫性，但這不代表臺灣將來應該如何制憲這個議題不重要。這是一個難以迴避的議題，但臺灣對於該如何制憲的相關程序環節，討論並不充分。這在某種程度上意味著鼓吹制憲者沒有仔細想過，一旦開啟制憲工程，其失敗的後果與政治意涵為何。制憲失敗絕非單純的浪費龐大的人力物力而已，國際經驗顯示，一旦制憲失敗，有時會使得立場

相反的他方，反而取得制憲的契機與正當性，進而制定出一開始試圖制憲者所不願看到的憲法內容³⁹。在這種情況下，如果能先討論將來制憲時所應注意的事項，將有助於減少社會大眾、特別是少數族群（包括國家認同的少數、原住民族……等），對於未來制憲所帶來的不確定感，進而降低制憲的政治與社會成本，提高制憲成功的機會乃至新憲法的品質。

事實上，正因為目前沒有制定新憲法的急迫性，反而更是一個仔細思考這個議題的好時機。其理由有二：首先，在憲法設計這個領域一個最大的矛盾就是：憲法往往是在最不適合制定一部新憲法的時候被制定出來⁴⁰。其原因在於制定一部新憲法的政治、社會成本過高，因此多數國家不會在承平時制定新憲法，而且承平時意味著政局穩定，因此也沒有迫切需要制定新憲法；換言之，通常只有在國家發生重大經濟、天然災難、或戰爭結束的時候，人民才會有制定新憲法的動機與決心。然而，天災人禍意味著龐大的時間壓力與迫在眉睫的問題，甚至心理學研究顯示，當遇到重大災難時，人們更容易盲目地相信與支持政府⁴¹。在這種情況下，不論是政客或一般人民，都更容易為一時的群情激昂或短視近利所迷惑，因而制定出有缺陷的憲法⁴²。

從這個角度來看，傳統上援引荷馬（Homer）史詩《奧德賽》（THE ODYSSEY）中，奧德修斯與女妖（Ulysses and the Sirens）的故

39 Mara Malagodi, *Constituent Assembly Failure in Pakistan and Nepal*, in CONSTITUENT ASSEMBLIES 79, 82 (Jon Elster et al. eds., 2018).

40 Jon Elster, *Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process*, 45 DUKE L.J. 364, 394 (1995); Andreas Braune, *Authoritative Constitution-Making in the Name of Democracy?*, in CONSTITUTIONALISM UNDER EXTREME CONDITIONS: LAW, EMERGENCY, EXCEPTION 323, 332-34 (Richard Albert & Yaniv Roznai eds., 2020).

41 Kai Chi Yam et al., *The Rise of COVID-19 Cases Is Associated with Support for World Leaders*, 117 PROC. NAT'L ACAD. SCI. 25429, 25429-33 (2020).

42 Jon Elster, *The Political Psychology of Constitution Making*, in CONSTITUENT ASSEMBLIES 207, 216 (Jon Elster et al. eds., 2018).

事，將憲法比喻成一個人在清醒時的預先自我約束⁴³，其實是相當誤導的，更貼近事實的情況可能恰好相反：憲法制定是一個人在酒醉的時候想要拘束往後清醒的自己⁴⁴。換言之，在承平時時期研究新憲法該如何制定，正是為了讓危急時期真正需要制定新憲法時，不至於手足無措或流於民粹。更何況新憲法的制定，本來就不必然意味著憲政發展的進步。事實上，一部新憲法的制定，同樣有可能是政治或經濟菁英為了進一步鞏固自己的特權，想將既得利益入憲的結果⁴⁵，例如中華人民共和國憲法的序言明定中國須由中國共產黨領導。又或是為了避免自己往後被清算，因此預先在新憲法中安排特定制度，以制衡新上臺的政權，像是部分東歐國家的憲法設計⁴⁶。甚至可能是野心家為了獨裁統治鋪路的前置作業，像是委內瑞拉、祕魯、和厄瓜多的制憲⁴⁷。因此如何避免新憲法的制定，淪為政治菁英的工具，部分取決於我們對制憲程序的理解與準備。

第二個原因則是類似無知之幕⁴⁸的概念，在承平時時期討論未來新憲法的制定方式，可以透過程序設計，例如規定所通過的新憲法必須經歷一次全國大選後才能生效，進而創造憲法政治上的無知之幕。由於政治局勢在未來會如何發展，哪個政黨會在將來得勢，哪

43 JON ELSTER, ULYSSES AND THE SIRENS: STUDIES IN RATIONALITY AND IRRATIONALITY 94 (1979).

44 JON ELSTER, ULYSSES UNBOUND 88-174 (2000); Elster, *supra* note 42, at 242; Braune, *supra* note 40, at 332. 國內對此的介紹，請參閱蘇彥圖，憲政民主的死人之手問題——憲法規範權威的初步反省，收於：李建良編，憲法解釋之理論與實務（九），頁152-157（2017年）。

45 MICHAEL J. KLARMAN, THE FRAMERS' COUP: THE MAKING OF THE UNITED STATES CONSTITUTION 5 (2016); Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq, *Introduction: From Parchment to Practice*, in FROM PARCHMENT TO PRACTICE: IMPLEMENTING NEW CONSTITUTIONS 1, 3 (Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq eds., 2020).

46 Elster, *supra* note 42, at 215.

47 David Landau, *Constituent Power and Constitution Making in Latin America*, in COMPARATIVE CONSTITUTION MAKING 567, 577-80 (David Landau & Hanna Lerner eds., 2019).

48 JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 136-42 (1971).

個政黨會掌握哪個憲法機關，都是未知之數，因此在討論如何制定新憲法的時候⁴⁹，制憲者將面臨各種不確定性，比較不容易有本位主義或因人設事的情況產生，甚至可能因為擔心當無知之幕揭開時，自己是屬於政治上弱勢的一方，而會更著重制定一部不論在權力分立或基本權利面向上，都更保障少數的憲法，以避免自己落入最糟的境地。

基於這兩個原因，本文認為現在正是討論將來該如何制定新憲的好時機。而一部新憲法的制定，從制度面來說⁵⁰，第一個要討論的問題是：制憲應該依循什麼途徑？這問題涉及對制憲權的想像與理解。扼要地說，傳統理論認為制憲權就是赤裸裸的權力的展現，因此不受任何舊政權的既有法律所規制；比較新的理論則認為制憲權是一種憲法化的權力，得依現有的規範，變更或取代既存的憲法秩序⁵¹。許多重要的法哲學家與政治哲學家都曾就此一概念提出自己的看法，孰是孰非並非本文所要深究的對象，之間的差異也非上述簡化的二分法可以詳述。對本文來說，重要的是這些差異部分起源於所觀察的制憲模式有所不同⁵²，在過去，多數憲法都是革命後的產物，不論是18世紀末期、兩次世界大戰結束、或是1980年代，其制定憲法的主要目的在於否定過去的法秩序（君權、殖民母國、

49 ADRIAN VERMEULE, *MECHANISMS OF DEMOCRACY: INSTITUTIONAL DESIGN* WRIGHT SMALL 31-33 (2007); Alicia L. Bannon, *Designing a Constitution-Drafting Process: Lessons from Kenya*, 116 YALE L.J. 1824, 1851-53 (2007).

50 有些制度上問題，由於與臺灣脈絡相關性甚低，因此就不在本文的討論範圍。例如制憲委員會開會地點，是否會影響制憲過程的公開性，考量臺灣地狹人稠，以及現代的科技發展，在哪開會似乎並無決定性的差異；或是某些剛解殖的國家，由於還沒有憲政發展的經驗，因此會邀請外國人來參與制憲，這些都與臺灣的情況相距甚遠，因此便不多花篇幅介紹。

51 JOEL COLÓN-RÍOS, *CONSTITUENT POWER AND THE LAW* 4-12 (2020); MARTIN LOUGHLIN, *THE IDEA OF PUBLIC LAW* 99-113 (2003); ANTONIO NEGRI, *INSURGENCIES: CONSTITUENT POWER AND THE MODERN STATE* 1-34 (Maurizia Boscagli trans., University of Minnesota Press 1999) (1992).

52 MICHEL ROSENFELD, *THE IDENTITY OF THE CONSTITUTIONAL SUBJECT: SELFHOOD, CITIZENSHIP, CULTURE, AND COMMUNITY* 188-209 (2009).

共產極權)，因此對於制憲權的理解，多半傾向第一種；然而，時至今日，已經有一些新憲法是在民主時期所制定，在這種情況下，制憲權的行使不再是單純政治實力的展現，對於既有的法秩序，也無須全面否定，而得以依循現行的法規範所行使⁵³。就此，有些國家會在既有憲法中規定如何制定下一部新憲，這些規定甚至細膩到制憲委員會該如何產生，需要多少選民聯署才能提案、以及新憲法在什麼情況下會生效。

當然，中華民國憲法並沒有規定如何制定下一部憲法，這是個法制面上的空白，基於現實上的政策考量，如果未來臺灣朝野人民都有共識要制憲的話，可能有三種途徑：

第一種途徑可稱為船到橋頭自然直。如果我們沿襲著上述傳統對於制憲權的理解，則無須事先規範如何制憲，因為任何不論是修改現行憲法，以加入對於制憲的規範，或是逕以修憲的門檻和程序進行制憲，甚至是以法律規定制憲程序，都象徵著人民的制憲權、以及新憲法，受到既有憲政秩序的拘束，這牴觸了制定新憲法的目的就在於建立新的憲政秩序。換句話說，制憲就應該是革命性的、破壞性的、顛覆性的。如果臺灣真的有制憲的急迫需要時，在那個憲法時刻，人民自然會產生出一套臨時機制來制定憲法，這也是制憲與立法在程序面上最大的不同。反過來說，就算我們現在制定任何規範，如果後來因為各種原因（例如臺灣發生戰亂或天災人禍），導致臺灣人民無法依照既有規範來制定憲法，那麼那部不依既有規範制定的新憲法，當然還是有效，其理由在於當遇到這種非常時期，既有現存的法秩序很可能都已經遭懸置，在這種危急關頭，要強求制定新憲仍要按照一定程序，未免在政治上過於不切實際，而且也違反人民的期待。一言以蔽之，現在規範如何制憲，不

53 Joel Colón-Ríos, *Constitution Making through Law, in REDRAFTING CONSTITUTIONS IN DEMOCRATIC REGIMES: THEORETICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVES* 33, 34 (Gabriel L. Negretto ed., 2020).

但與傳統制憲權的理解有所扞格，該規範對往後的制憲可能也沒有任何拘束力。採取這種途徑的優點在於可以避免許多憲法理論上的爭議，而且可能也最符合傳統對於制憲的想像，缺點就是制憲工程缺乏可預測性以及穩定性，因此可能為民粹或獨裁者所操弄，進而制定出糟糕的新憲法。

第二種途徑則是舊瓶裝新酒，以現行憲法條文所規範的修憲程序，包括門檻與發起方式，來制定下一部新憲。而這裡所謂的制定新憲，又可以區分兩種情況。第一種是真的制定一部新憲法，例如波蘭，在民主化初期並沒有制定新憲法，而是先修改舊憲法產生新的國家機關，再逐步藉由既有的修憲機制，制定新憲法⁵⁴；第二種則是制定一部形式上是憲法修正條文，但實質上由於變動程度過大，被認為是新憲法，這種「制憲、修憲相對化」的情況，是許多民主轉型國家憲法變遷的特色⁵⁵。而所謂相對化，除了憲法變遷的管道相對化之外，也包括憲法變遷的程度，例如南韓便曾以既有的修憲規定進行實質上制憲，形式上雖是第九次修憲，但修改程度實質上卻是新憲法。這種模式雖然程序上是遵循舊的修憲機制去進行制憲，但內容變更的程度可能相當大，甚至包括國體和國號，因此未必真的受到舊憲政秩序的拘束⁵⁶。事實上，這也是 Venice Commission 所推薦的模式，其理由在於這樣可以使制憲過程更和平，同時新憲法也將更為穩定、正當、與合法⁵⁷。除此之外，這種途徑最主要的優點就是提高可預測性與（憲）法的延續性（legal continuity），因為所有行動者，包括全國人民，不但在事前就明瞭

54 吳玉山，政權合法性與憲改模式：比較台灣與歐洲後共新興民主國家，收於：吳重禮、吳玉山編，*憲政改革：背景、運作與影響*，頁37-39（2006年）。

55 葉俊榮、張文貞，*路徑相依或制度選擇？論民主轉型與憲法變遷的模式*，*問題與研究*，45卷6期，頁19-21（2006年）。

56 葉俊榮、張文貞（註55），頁17。

57 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Report on Constitutional Amendment, ¶ 68, Study no. 469/2008 (Jan. 19, 2010).

制憲機制為何，而且對於這個機制相當熟悉，甚至實際操作並以此修憲過，因此在程序上起爭議的可能性較小，制憲過程可能會較為順利。

然而，在理論上這麼做會引起一個爭議，亦即制憲之所以有別於修憲，就在於後者仍受到既有憲政價值的限制，包括臺灣在內，有越來越多的國家承認修憲必須在一定的界線內⁵⁸，一旦踰越此一界線，縱使修憲條文得到民眾的支持，司法部門既有權也有必要將之宣告違憲而無效；相對地，制憲並不受既有憲政秩序的拘束，甚至可能正是為了改變既有憲政秩序而產生，因此自不受修憲界線之限制。倘若我們以現行憲法中的修憲程序去規範新憲法的制定，可能會產生新憲法是否受到舊憲政秩序約束的疑慮。就此，這涉及上述對於制憲權的討論，如果秉持著傳統的理解，那麼確實可能有此疑問，然而時至今日，不但在學說上這種傳統理解已經逐漸被鬆動⁵⁹，實務上也已經有國家以修憲程序制定新憲法。此外，採取這種途徑另一個潛在的缺點是，如果先前的憲法秩序屬於舊威權政體的一部分，那麼這種法的延續性可能會阻礙民主轉型和政治自由化⁶⁰，因此有學者主張在威權轉型的脈絡下，新興民主國家仍應當用全新的程序來制定一部新憲法，以象徵國家的新生⁶¹。

在臺灣的脈絡下，另一個可能的爭議是，現行修憲程序的規定，文義很明白是指修改憲法，而非制定一部新憲法，如果要以此作為制憲的規定，在解釋上可能會有困難。然而，這個困難可以透

58 YANIV ROZNAL, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS: THE LIMITS OF AMENDMENT POWERS 5-12 (2016).

59 ANDREW ARATO, POST SOVEREIGN CONSTITUTION MAKING: LEARNING AND LEGITIMACY *passim* (2016).

60 GARY JEFFREY JACOBSON & YANIV ROZNAL, CONSTITUTIONAL REVOLUTION 73-74 (2020); Yaniv Roznai, *Constitutional Transformation: Hungary, in* CONSTITUTIONALISM IN CONTEXT 136, 155 (David S. Law ed., 2022).

61 BRUCE ACKERMAN, THE FUTURE OF LIBERAL REVOLUTION 61-62 (1992).

過兩種方法解決，第一種是挪用修憲的程序要件，但並非直接適用憲法增修條文第12條，也就是說，主要政黨間有共識以修憲的程序要件作為將來制憲的程序要件，但概念上並不是開啟修憲程序。另一個可以考量的方法是以修改為名，實質上制定一部新憲法，如此可以避免上述文義限制，而且從他國的經驗看來，如果連國號都可以透過修憲變更的話，似乎只要在遵守司法院釋字第499號解釋所畫下的修憲界線內（因為此方法形式上仍是修憲），也沒有什麼不可以修改的。考量到制憲之於臺灣宣布獨立的象徵意涵，臺灣制憲不僅受到中國的武力威脅，也未必會受到美國與其他民主國家的支持，這種國際政治的現實，使得透過修憲程序來制憲，由於形式上是修憲，可能引起的反彈較低，或許不失為一個可以考慮的作法。但這兩種方法都還會遇到另一個問題，也就是我國修憲的門檻——四分之三的國會同意加上選舉權人（而非投票人）過半數同意——從世界各國的標準來看，實在過高。事實上，有許多研究試圖測量世界各國修憲的困難程度，在這些文獻中，即便是那些沒有囊括臺灣在內者，由其測量方法來看，臺灣修憲難度也都屬於世界上最困難的層級⁶²。如果單從形式要件來看⁶³，也就是國會通過門檻加上人民公投門檻，在非聯邦制的國家中，幾乎找不出比臺灣修憲更困難的國家。因此，有學者指出，如果修憲門檻高到幾乎不可能進行憲法變遷，那麼透過其他方式規畫制憲權的行使，將是可能的出路⁶⁴，這就涉及下述第三種途徑。

62 Astrid Lorenz, *How to Measure Constitutional Rigidity*, 17 J. THEORETICAL POL. 339, 339-61 (2005); EDWARD SCHNEIER, CRAFTING CONSTITUTIONAL DEMOCRACIES: THE POLITICS OF INSTITUTIONAL DESIGN 222-25 (2006); DONALD S. LUTZ, PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL DESIGN 170-82 (2006); AREND LJPHART, PATTERNS OF DEMOCRACY 206-11 (2012).

63 當然，修憲困難與否，有時候取決於一國無形的憲政文化，而非全然取決於門檻高低。Tom Ginsburg & James Melton, *Does the Constitutional Amendment Rule Matter at All? Amendment Cultures and the Challenges of Measuring Amendment Difficulty*, 13 INT'L J. CONST. L. 686 (2015).

64 Colón-Ríos, *supra* note 53, at 50.

如果我們認為第一種途徑太過無法預測，而第二種途徑，在臺灣的脈絡下又太過僵化，那麼第三種途徑則是經由透過主要政黨的協商，以簽署備忘錄的形式，載明相關程序內容，包括門檻、制憲委員會的組成、人數、與討論時間、憲法草案機關、制憲原則等程序性事項，之後待時機成熟時，再開啟制憲工程。這種途徑的優點在於避免第一種途徑的不可預測性，同時又保留彈性。但這種途徑將面臨三個問題，第一個是可以用政黨備忘錄來規畫新憲法的制定嗎？這在第二種模式也會產生類似的問題，也就是新憲法的制定，是否得事先規畫？然而事先規畫並不意味著人民的制憲權以及新憲法受到拘束，因為即使我們承認制憲權的行使不應受任何限制，但制憲權的行使現實上仍仰賴國家機關在行政業務上的協助，因此必須事先讓所有人知道該如何行使⁶⁵，以免大家莫衷一是，反而癱瘓了制憲權⁶⁶，甚至進而對制憲結果產生質疑。在這個前提之上，只要不涉及實質內容⁶⁷，其實都是在協助人民行使制憲權，而非限制人民。其次，要將哪些政黨納入討論、連署？就此，一開始或可邀請所有在立法院有一定席次的政黨都參與討論，而不僅止於兩大黨。當然，現實上小黨可能隨著時間消逝，同時可能有新興政黨產生，不過只要兩大黨願意聯署，備忘錄存在就有其意義，其他小黨或新興政黨自可隨時加入或退出。最後一個問題則是備忘錄有拘束力嗎？就這點而言，政黨之間所形成的備忘錄，縱使形諸文字，當

65 William Partlett, *Expanding Revision Clauses in Democratic Constitutions*, in REDRAFTING CONSTITUTIONS IN DEMOCRATIC REGIMES: THEORETICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVES 53, 59-60 (Gabriel L. Negretto ed., 2020); Yaniv Roznai, "We the People", "Oui, the People" and the Collective Body: Perceptions of Constituent Power, in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL THEORY 295, 303 (Gary Jacobsohn & Miguel Schor eds., 2018); Yasuo Hasebe, *On the Dispensability of the Concept of Constituent Power*, 3 INDIAN J. CONST. L. 39 (2009).

66 JACOBSON & ROZNAI, *supra* note 60, at 259.

67 Colón-Ríos, *supra* note 53, at 49-50. 當然，一旦有任何程序性規定，縱使其目的不在於限制人民權利，仍免不了會涉及人民權利，例如假設該程序規定制憲委員會組成必須保留原住民和婦女席次，則自然會引起平等權的爭議，這是任何法律都無法避免的情形。

然也沒有法律上的拘束力。但這不代表制定備忘錄沒有意義，相反地，備忘錄可以發揮兩種作用：首先，它可以發揮協調（coordination）的功能，一旦將來制憲時機產生，政黨之間將可以透過事先簽定的備忘錄，預測其他政黨會如何反應，並進而決定自己該如何行動；其次，白紙黑字的備忘錄，就算沒有法律上拘束力，在政治上仍將對所簽署的政黨產生一定的政治壓力，使其不致輕易變更承諾。

這三種途徑，各自有其優缺點，第一種途徑爭議可能最小，但也最難預測；第二種途徑理論上最明確，但考量臺灣的修憲門檻，似乎最難執行；第三種途徑似乎避免了前兩種模式的缺點，但更依賴政黨政治的運作。臺灣要採取哪一種途徑，取決於每個人認為在憲法變遷的過程中，最重要的特性是什麼：是保持開放性？還是維持穩定性？抑或者是彈性？事實上這三種並不全然衝突，即便採取第三種途徑，也可能政黨協商的結果最後決定援用修憲規定辦理，或者部分採取修憲規定；而縱使認為應採取第一種途徑不得事先規範，也不可能阻止相關議題的討論。本文認為，為提高制憲可預測性，臺灣未來制憲應避免採取第一種途徑，至於剩下兩種，本文認為皆無不可，端視人民是否會選擇避險（risk-averse），寧可因超高門檻而相當程度犧牲制憲的權力。

值得強調的是，不論採取哪一種途徑，其用意都不是以制憲程序取代修憲程序。臺灣將來如何制憲是一個法制面上的空白。既然本來是空白，不論採取哪一種模式，自無所謂取代的問題。換言之，既有修憲的途徑仍然不受影響，如果臺灣人民願意依循該途徑進行修憲，其修憲自然仍為有效。兩套程序是併行的。此外，制憲與修憲在客體上也有所不同。在臺灣，基本上已經確立了修憲有界限論，換句話說，得修憲的內容與得制憲的內容並不完全相同。再者，制憲由於其政治意涵，所帶來的風險遠高於修憲，不論這個風險指的是國際政治的因素還是國內政局的動盪，這點是想利用制憲

進行憲法變遷工程的政客所必須考慮的。因此基於這種利益衡量，也不必然就會採取形式上門檻較低、但實質上風險較高的制憲。舉例來說，如果今天只是想要把投票年齡往下修，而不涉及其他憲法條文，即便臺灣有制憲程序規範，在考量制憲所將引起的國際風險時，多數人仍會選擇修憲，而非大張旗鼓的制憲。一言以蔽之，形式上門檻的高低，並不必然意味著實質上執行的難易。

最後要釐清的是，不論採取哪一種途徑，都不預設未來新憲法的國家認同、基本權利內涵，或政府體制，因此不論是鼓吹統一、多元成家、或內閣制度，都有可能依照相關規定開始制憲工程。本文不是在鼓吹臺灣應當立刻制憲，事實上這正是本文在之前所反對的；本文所建議的是目前應當好好討論制憲程序，以備不時之需，至於這個不時之需什麼時候會來臨，本文無法預測。

參、制憲程序

如上所述，本文認為臺灣雖然有制憲的實益，但目前應先對制憲過程所需要的程序規範有所共識，這些程序規範包括行使制憲權主體、制憲草案產生方式、制憲會議的人數與組成、制憲應遵從的原則、司法審查與否……等問題。不論要採取第一種或第三種途徑，都會面臨這些問題。即便是採取第二種途徑，也就是借用修憲規定進行制憲，但我國憲法增修條文第12條，除了明定立法院提案的門檻以及公民複決的門檻之外，對於上述這些問題，許多也沒有規定。換句話說，因此不論採取哪一種途徑，都仍有討論這些問題的必要。

一、行使制憲權主體

中華民國憲法本文雖然有規定直接民權，但均以國民大會來代

替人民行使。在廢除國民大會後，憲法增修條文第1條規定人民得複決憲法修正案與領土變更案。然而，多數憲法並未規定自己該如何被廢止，以及廢止後下一部新憲法該如何產生⁶⁸，中華民國憲法也不例外。因此產生了一個看似簡單但卻沒有任何法規依據的問題：誰來行使制憲權？這答案當然是臺灣人民，但該如何行使？依據在哪？從比較憲法來看，在搜尋完現行所有國家的憲法⁶⁹之後，本文發現在現行憲法中規範如何開啟制憲程序的國家，多半不是臺灣法學研究者比較熟知的國家（像是美國、德國、日本、法國），例如厄瓜多的2008年憲法第444條⁷⁰規定制憲大會得應總統、三分之二的國會議員、或12%的選民要求召開；玻利維亞憲法第411條⁷¹則是規定總統、國會過半、以及20%的選民；巴拿馬憲法第314條⁷²

68 David Landau, *Abusive Constitutionalism*, 47 U.C. DAVIS L. REV. 189, 242 (2013) (“At the level of constitutional design, relatively few constitutions contain any clause to regulate their own replacement”). Landau, *supra* note 47, at 581-83.

69 Comparative Constitutions Project, Constitutions, CONSTITUTE, <https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=en> (last visited Feb. 13, 2022).

70 Article 444 of the Constitution of The Republic of Ecuador: “Installation of a Constituent Assembly can only be called by referendum. This referendum can be requested by the President of the Republic, by two thirds of the National Assembly or by twelve percent (12%) of the persons registered on the voter registration list. The referendum must include how representatives must be elected and the rules for the electoral process. The new Constitution, for its entry into force, shall require adoption by referendum with half plus one of all valid ballots cast.”

71 Section I, Article 411 of the Constitution of Bolivia: “I. The total reform of the Constitution, or that which affects its fundamental premises, affects rights, duties and guarantees, or the supremacy and reform of the Constitution, shall take place through an original plenipotentiary Constituent Assembly, put into motion by popular will through referendum. The convocation of the referendum shall be carried out by citizen initiative, with the signatures of at least twenty percent of the electorate; by absolute majority vote of the members of the Pluri-National Legislative Assembly; or by the President of the State. The Constituent Assembly (Asamblea Constituyente) shall draft its own regulations for all effects. The constitutional text must be approved by two-thirds of the members present. The validity of the reform shall require approval by constitutional referendum.”

72 Section 1, Article 314 of the Constitution of Panama: “A new Constitution may be adopted by a Parallel Constituent Assembly (Asamblea Constituyente Paralela) which may be convened by decision of the Executive Branch, ratified by the Legislative

也有類似規定，只是門檻略為提高，變成行政部門加國會過半、或是三分之二的國會議員、或是20%的選民。

未來臺灣制憲前，如果在制憲時選擇借用現有的修憲程序來制憲，那麼提案權主體已經有既定的規範，也就是交由立法院開啟。但如果不是，是否需要賦予人民、立法院、或總統權力，即不無疑問。就人民而言，有鑑於在臺灣的脈絡下，制憲是一件格外敏感的議題，不但涉及國內憲法政治，更可能引起國際矚目，影響東亞情勢。再加上國內目前公投頻繁，可以想見的是一旦將此一權力交給人民，將可能使政府疲於應付制憲提案，因此本文初步認為還是應當將人民提案的權力，委由同樣理念的政治菁英行使。如此一來，一方面可以讓想要制憲的人民，透過施壓政治菁英，對於開啟制憲程序有一定程度的影響力，另一方面政治菁英彼此之間透過制衡、妥協，以及政治課責，相對來說可能比較不會有暴衝的情形。至於政治菁英提案的門檻要多少，在比較憲法上，有些國家會賦予總統和一定人數（例如三分之二）的國會議員提案制憲的權力。就立法院而言，本文認為也可比照辦理，以避免極少數政黨因具有提案否決權，而壟斷制憲的權力。而就總統而言，由於總統是一人獨斷，相對於國會，比較有濫權的可能，再加上我國選舉制度下，可能產生少數總統（總統得票低於投票數一半且所屬政黨在國會僅佔少數席次），因此本文認為如果要賦予總統提案制憲的權力，則應當加上國會過半同意的要件，以確保提案本身具有一定的民意支持度。

二、憲法草案產生機關

一旦開始制憲，第一個要處理的問題就是憲法草案要由什麼

Branch with absolute majority, or by the Legislative Branch with a favorable vote of two thirds of its members, or by popular initiative which must be signed by at least twenty percent (20%) of citizens enrolled in the Electoral Register on the thirty-first of December of the year preceding the initiative....”.

「制憲委員會」產生？首先要注意的是，這個委員會未必要從頭開始，可以考慮先交由特定少數人草擬一份憲法草案作為討論的藍本，然後再交由制憲委員會討論以形成最後的草案版本，並提出給全民批准。這麼做雖然可能會有賦予少數人過大權限的疑慮，但由於一開始的這個版本充其量僅是未來憲法草案的草案，其內容還會經過制憲委員會審議討論，以及最後的全民批准，因此或許不必太擔心這個問題。相對地，這麼做的好處是一開始的草案由少數人產生，會比較有融貫性⁷³，減少多頭馬車或前後矛盾的可能性，而且可以降低制憲委員會所需要的時間。另外一個相反的做法是先選出一群人進行討論，並提出將來要放在憲法草案的大原則與方向，再將這些原則與方向交給另一群人數較少的制憲委員會形諸文字，最後提交全民批准，像是冰島在2010年間就採取這種方式。

至於制憲委員會本身如何產生，從比較憲法的觀點來看，常見的有三種模式：一種是在既有的立法機構之外，另行選舉產生一個專責制憲、且在提出或批准憲法草案之後，旋即解散的制憲委員會；第二個模式是直接由既有的立法機關提出憲法草案，也就是說制憲委員會就是國會，即使該機關本來並未被明文賦予這項職權，這也是歷史上最常發生的狀況⁷⁴；第三個模式則是成立制憲委員會，這些委員會除了提出憲法草案外，也會在制憲後繼續承擔立法工作⁷⁵。這三種模式當然沒有窮盡世界各國的經驗，而只是比較常出現的情形。每一種組成方式都各自有其優缺點，而各國要採取哪種模式，最重要的考量標準就是在該國的歷史、政治、社會條件允

⁷³ Bannon, *supra* note 49, at 1854-57.

⁷⁴ Dennis C. Mueller, *On Writing a Constitution*, in RULES AND REASON: PERSPECTIVES ON CONSTITUTIONAL POLITICAL ECONOMY 9, 20 (Ram Mudambi, Pietro Navarra & Giuseppe Sobbrío eds., 2001); William Partlett, *The Dangers of Popular Constitution-Making*, 38 BROOK. J. INT'L L. 193, 206 (2012).

⁷⁵ Jon Elster, *Legislatures as Constituent Assemblies*, in THE LEAST EXAMINED BRANCH: THE ROLE OF LEGISLATURES IN THE CONSTITUTIONAL STATE 181, 183 (Richard W. Bauman & Tsvi Kahana eds., 2006).

許的範圍內，哪一種模式最能強化新憲法的民主正當性，並避免制憲委員在制憲過程中，以及制憲結束後的圖利行為。

就第一種模式來說，由於人民很清楚選舉制憲委員之目的就是為了制憲，而憲法草案公布後，制憲委員也不會自動繼續承擔任何職務，因此不但所提出的草案會比較具有民主正當性，理論上在制憲過程中，制憲委員也比較不會偏好特定部門，因為他們縱使沒有解甲歸田，也無法確定自己未來會在政府中的哪一個部門工作。這種模式的缺點則在於要在既有的國會之外，另外選舉產生制憲委員會，本身就會耗費不小的時間與金錢成本；而且由於兼具能力與經驗的政治工作者可能在現實上數目有限，如果國會成員不能兼任制憲委員，那制憲過程的效率以及最終憲法草案的品質可能堪憂⁷⁶。

就第二種模式而言，雖然看起來是明顯的越權，但如上所述，由於一部憲法通常只會規定如何被修改，而鮮少規定其如何被取代，再加上通常只有在國家面臨危難時，人民才有足夠的動機與共識制定新憲法，因此在這種兵荒馬亂或百廢待舉的時期，仰賴一個現存的合議機關，常常也是在現實壓力下最好的選擇。選擇這種模式的好處在於相對於其他模式，其召集成本非常低且快速，也因此讓後續的制憲討論與批准過程，有更多緩衝的時間⁷⁷。而且理論上立法委員對於議事程序熟稔⁷⁸，且立法機關具有一定程度的民意支持，相較於由行政權提出憲法草案，合議制產生的憲法草案或許更能避免個人利益凌駕憲政理念的情況。而且如果立法委員在制憲過程中，有任何不正當的情事產生，選民還可以在下一次國會選舉中究責。最後，部分東歐國家的經驗顯示，由於政治菁英的彼此制衡，由議會主導的制憲反而可以更充分的審議思辨；相反地，一旦訴諸既有體制外的制憲委員會或公投，反而容易被特定政治菁英透

⁷⁶ *Id.* at 196.

⁷⁷ Mueller, *supra* note 74, at 20.

⁷⁸ *Id.*

過操弄選舉而濫用制憲權⁷⁹。這種模式的缺點在於立法委員當初並沒有被賦予制定憲法草案的職權，而人民對於選舉立法委員和選舉制憲委員可能有不同的期待與標準，因此在這種模式下所提出的憲法草案，在民主正當性上就會有所折扣⁸⁰。此外，憲法與一般法律的目的有所不同，前者在於凝聚國民全體，而後者則在於使政府治理更有正當性與效率，從這個角度來看，通過憲法草案的門檻也不應與法律案一樣⁸¹。此外，會推動重新制憲的原因就在於對原本憲政秩序的不滿意，而國會屬於舊憲政秩序的一環，可能正是新憲法所要改革的對象，因此交由國會產生新憲法草案，可能在正當性上有所不足⁸²。最後，由於立法委員本身就有自己的選區與選民，因此更可能在制憲過程中受到不當的影響⁸³，或是預測自己仍會繼續當選，因此過度擴張立法權限⁸⁴。

至於最後一種模式，通常發生在民主轉型國家，由於其目的一開始就是為了制定憲法草案，從這個角度來說，草案會較第二種模式更具民意基礎，但由於制憲委員將在接下來續任立法委員，因此可能在草案中不當擴張立法權，而犧牲其他部門的權力⁸⁵。而且第

79 William Partlett, *The Elite Threat to Constitutional Transitions*, 56 VA. J. INT'L L. 407, 453-57 (2016).

80 Elster, *supra* note 75, at 186; Mueller, *supra* note 74, at 24.

81 Elster, *supra* note 75, at 186-87.

82 JOEL COLÓN-RÍOS, WEAK CONSTITUTIONALISM: DEMOCRATIC LEGITIMACY AND THE QUESTION OF CONSTITUENT POWER 159 (2012).

83 Elster, *supra* note 75, at 189; Mueller, *supra* note 74, at 20-21.

84 ARATO, *supra* note 59, at 11, 119; VERMEULE, *supra* note 49, at 10-11; Mueller, *supra* note 74, at 21. 值得一提的是，這種直覺上很合理的預測，雖然在某些國家確實有發生，但實證研究數據不支持。Justin Blount et al., *Does the Process of Constitution-Making Matter?*, in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL DESIGN 31, 48 (Tom Ginsburg ed., 2012); Gabriel L. Negretto, *Constituent Assemblies in Democratic Regimes: The Problem of a Legally Limited Convention*, in PERSPECTIVES ON CONSTITUENT ASSEMBLIES 31, 41 (Jon Elster et al. eds., 2018).

85 像是巴西現行的憲法，Keith S. Rosenn, *Brazil's New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for a Transitional Society*, 38 AM. J. COMP. L. 773, 773 (1990).

一種模式的弊病，像是召集成本、專業程度等，這種模式通常也會面臨同樣的質疑。最後，由於新成立的制憲委員會在制憲結束之前，就會承擔日常政治的立法工作，因此更有可能在制憲過程中，涉入政治鬥爭，進而使得制憲工程困難重重⁸⁶。

在這點上，中華民國憲法當初制定時，是採取第一種模式，也就是另行透過選舉及保留名額產生制憲國民大會代表，且制憲國代在憲法公布後並不當然續任國民大會代表，第一屆國民大會代表是另行選舉產生。這本來應當是最具有民主正當性的一種選擇，問題在於制憲國大選舉過程的漫長，削弱其民主正當性。詳言之，在1936年五五憲草公布後，國民政府本欲盡快召開制憲國民大會制定憲法，因此旋即於同年公布國民大會代表選舉法，並於1937年初開始在全國各省開始選舉。但因為對日抗戰的結果，當時有一些省分實際上未能辦理選舉，導致制憲國民大會被迫延期，這一延就延到第二次世界大戰結束後。後來為了通過政治協商會議所提出的政協憲草，國民政府準備在1946年11月召開制憲國民大會，此時理應進行國民大會代表的全面重新選舉，但當時的國民政府並未如此做，而是一方面延用1937年的選舉結果，而在當年沒有完成選舉的部分，以遴選的方式產生其他代表⁸⁷。這一方面證實了第一種模式確實曠日費時、成本高昂，特別是在戰亂之後欲行使制憲權的時候，但另一方面也讓當年的制憲國民大會失去了第一種模式本應具有的最大優點，也就是民主正當性，畢竟9年前的選舉結果，顯然已經無法代表最新的民意。換句話說，當年的制憲過程，雖然選擇了第一種模式，但由於戰亂意外與政治計算，不但暴露了第一種模式的缺點，也失去了第一種模式的優點，而最終這也成為中國共產黨拒絕參與制憲國大的表面理由。

⁸⁶ 例如巴基斯坦與尼泊爾的制憲經驗，Malagodi, *supra* note 39, at 80-81.

⁸⁷ 荊知仁，中國立憲史，頁447-450（1984年）；郎裕憲、陳文俊，中華民國選舉史，頁215（1987年）。

如果將來臺灣要在承平時制憲，而且不是直接沿用修憲程序進行制憲的話，本文認為仍應當採取第一種模式，其理由就在於更具有民主正當性。一旦制憲委員交由立法院指派或由立法院產生，必然立刻引起立法院少數黨的質疑。至於制憲委員的身分是否應有所限制，若要避免立法權或行政權自肥，則有兩種最直接的方式，一是從上游管制，限制現任的立委或一定層級以上的行政官員不得參與制憲委員會⁸⁸。事實上這種類似的想法，在中華民國憲法設計的過程中也可以看到，目前已停止適用的第28條第3項規定「現任官吏不得於其任所所在地之選舉區當選為國民大會代表。」這條文雖然是基於過去政權與治權區分的憲法理論所設計，但要防止利益衝突的想法在一定程度上是類似的，畢竟過去國大代表行使的權力就包括修憲權。

當然，全面禁止政治實務工作者參與，可能會使憲法草案脫離政治現實太遠，導致不切實際的問題，如果要避免這個問題，就一定要有其他管道確保政治實務工作者的意見能夠被納入考量。因此也可以採取第二種防止利益衝突的辦法，也就是從下游管制，設定某些旋轉門條款⁸⁹，例如限制制憲委員不得參與下一屆立委選舉或總統選舉等設計。當然，這樣限制是否會造成具有足夠能力的制憲委員數目太少，這就牽涉到委員會本身大小的問題。

三、制憲委員會的人數、組成、與討論時間

制憲委員會要多少人，在世界各國差異甚大，從法國大革命後的1,200人，到冰島在21世紀初期的25人都有可能。在這點上，通常取決於一國人口的數量以及人口組成的同質性高低⁹⁰。一般說來，一國人口越多、或是人口組成的異質性越高（例如種族、語

⁸⁸ Bannon, *supra* note 49, at 1866-67; COLÓN-RÍOS, *supra* note 82, at 164.

⁸⁹ Mueller, *supra* note 74, at 24.

⁹⁰ Jon Elster, *The Optimal Design of a Constituent Assembly*, in COLLECTIVE WISDOM: PRINCIPLES AND MECHANISMS 148, 156 (Hélène Landemore & Jon Elster eds., 2012).

言、或宗教信仰高度歧異)，則制憲委員會的人數應該要越多，藉以反映多元意見，使新憲法更具有民主正當性，進而使新憲法更不容易被取代⁹¹。再者，制憲委員人數較多的話，將可降低個別委員對於憲法草案內容的決定權，對於利益團體來說，要進行遊說也更困難，這或許可以降低制憲委員受到的不當影響。當然，如果人數太多，制憲委員就更容易產生搭便車（free-riding）的狀況，進而使制憲過程的討論品質下降，產生前後理念彼此不融貫，甚至有所矛盾的內容⁹²；此外，委員數量本身並不必然等同於多元觀點，相反地，委員數量過多本身有可能使少數族群的代表，在討論與表決時更被邊緣化而淪為裝飾，更不利於多元性。最後，早在兩百多年前美國制憲時，James Madison就指出，如果參與制憲大會的人數太多的話，將使議事效率降低⁹³，此時如果沒有將大部分工作交給大會中的分組委員會的話，進而使制定憲法草案的過程更耗時。

在中華民國憲法草案撰擬的過程中，不論是早期的五五憲草或是後來的政協憲草，其撰擬草案的人數都極為精簡。以政協憲草為例，時任政治協商會議秘書長的雷震認為「憲法要有一貫性，不能雜湊成章，而實際執筆起草者只能由一人專任其事，不可能採用集體創作的……其時政協會議係定於是年5月5日召集國民大會，制定憲法，自非加緊完成這部制憲草案不可。我想必須在兩個月內研討完畢……⁹⁴」故將政協憲草的草擬工作交由張君勱一人。這段話不但涉及憲法草案制定的人數問題，同時也牽連到下一個問題：如果必須要有期限的話，我們應該要給制憲大會多久的時間？

制憲過程耗時多久，這個問題在各國的制憲經驗中也是相差甚多，從五個禮拜到十幾年都有，平均則約莫是1.3年⁹⁵。如果放任討

91 ELKINS ET AL., *supra* note 11, at 139.

92 Elster, *supra* note 90, at 158; Blount et al., *supra* note 84, at 50.

93 THE FEDERALIST No. 55 (James Madison).

94 雷震，中華民國制憲史——政治協商會議憲法草案，頁105、109（2010年）。

95 Blount et al., *supra* note 84, at 41.

論而完全沒有限制制憲草案出爐的時間，那麼有些制憲委員可能會刻意拖延時間，以取得對其有利的結果⁹⁶。因此許多國家都會要求制憲委員會在一定期限內提出憲法草案，至於這個理想的期限，取決於我們對於制定憲法草案過程中，所要求的幾個原則有多堅持，像是公開性原則或是明確性原則（詳如下述「參、四」）。簡言之，如果在制憲的過程中，允許對於討論的部分保持相當程度的秘密的話，那麼制憲所需要的時間可能會比較短；反之，如果要求制憲過程全程公開的話，討論將可能更費時，這不但因為在全國矚目的狀況下，制憲委員比較不容易妥協，而且部分委員或許會想透過公開場合博取版面，進而圖謀個人利益。此外，制憲委員會於憲法草案的內容要求，不論是在憲法規範的廣度（例如權利清單的長度）或規範密度（例如我國憲法第8條關於人身自由鉅細靡遺的規定），如果更著重明確性的話，那麼討論也會更費時，自然會需要更多時間⁹⁷。最後，如果新憲法內容與前一部憲法的差距不大的話，那麼所需要的時間可能不會太久；反之如果新憲法徹底改頭換面，那麼自然會更耗時⁹⁸。

至於這些制憲委員該包括哪些人，則是另一個棘手的問題。由於憲法最重要的功能之一就是凝聚全國共識、形塑政治共同體，因此成員的多元性與包容性自然更為重要，這指的是在憲法制定的過程中，制憲委員應當在不妨礙議事進行與效率的前提下，儘可能的反映不同的聲音，因此制憲委員背景也應該儘可能的多元化，以確保新憲法足以反映少數意見，避免社會多數將主流價值觀（例如家父長制度或是異性婚制度）入憲。強調多元與包容的目的在於提高新憲法的民主正當性，並藉此提高國民對於新憲法的認知與支持，

⁹⁶ Jon Elster, *Clearing and Strengthening the Channels of Constitution Making*, in *COMPARATIVE CONSTITUTIONAL DESIGN* 15, 24 (Tom Ginsburg ed., 2012).

⁹⁷ Elster, *supra* note 90, at 159.

⁹⁸ Walter F. Murphy, *Designing a Constitution: Of Architects and Builders*, 87 *TEX. L. REV.* 1303, 1311 (2009).

其理由在於在制憲過程中，如果有數量越多、背景越多元的制憲委員參與，那麼可以合理推測的是，這些參與者作為某個族群的代理人，其背後所代表的族群，不但更容易透過代理人理解憲法草案的內容，在情感上也更容易對憲法草案產生認同感，認為這是一部屬於「他們的」憲法，而不論是對憲法內容的熟悉或是情感因素，都有助於提高這些族群對於新憲法的擁護⁹⁹。當這些族群的數量越多時，新憲法自然越受支持。

如果未來臺灣制憲是沿用修憲程序的話，制憲委員就是立法委員，自然沒有數量和背景的問題。如果採取其他制憲途徑的話，就中華民國在1946年的制憲經驗來說，當年的制憲國民大會，從1946年11月15日召開，直到同年12月25日，僅花了一個多月。如果再將政治協商會議後的制憲草案審議委員會算進去，亦僅花了將近一年。因此未來臺灣制憲時，考量到臺灣並非從零開始，一個合理的時間應當要求制憲委員會在一年之內提出草案。當然，如果在此之前，已經有一部由少數人先草擬的憲法草案作為討論藍本，則時間更可大幅縮短。至於人數而言，當年制憲國代本來預定的人數是2,050人¹⁰⁰，而中華民國當時人口約莫為4.6億人¹⁰¹，大概每22萬人中產生一名代表。如果考量到臺灣立法院約莫也是20萬人產生一名的話，以人口比例來說，未來在臺灣要制憲，100位左右的制憲委員應該是個合理的數字。

至於制憲委員的背景組成，中華民國憲法在制定時，當年制憲國民大會的組成，主要是以政黨多元性以及省籍多元性為主，因為當時國共內戰已經硝煙四起，一開始在美國的壓力下，為了安撫中國共產黨，而召開政治協商會議，由國民黨邀請其他幾個主要的政

⁹⁹ ELKINS ET AL., *supra* note 11, at 78-81.

¹⁰⁰ 參見荊知仁（註87）。

¹⁰¹ 楊家駱，大陸淪陷前之中華民國：民國卅七年份中華年鑑，第二卷，頁87（1973年）。

黨參與。而在國共內戰日趨白熱化之後，為了維持制憲國大仍屬跨黨派合作的形象，藉此維持中華民國憲法的民主正當性。這些政黨也都在制憲國民大會時擁有保障名額。此外，除了政黨保留名額與區域選舉名額外，尚有特種選舉（蒙藏、軍隊、僑民……等）和職業選舉，至於其他多元性的要求，則付之闕如。以性別為例，女性在全世界的制憲經驗中，都是容易被忽略的族群¹⁰²，當年中華民國憲法制定時，由於國民大會代表選舉法並無規定性別保障名額，而在選舉補充條例中也僅有規定20名婦女代表，因此在整個出席的1,701位制憲國代中，僅有80名女性（4.7%）¹⁰³，使得現行憲法第7條雖然保障性別平等，但婦運團體在制憲國民大會中的努力，包括推動婦女保障名額條款入憲等，則均告失敗，中華民國憲法也因此被批評為是一部「男人的憲法」¹⁰⁴。

當年這些設計固然有其時代背景，但不論是政黨保障席次或是職業代表，均與現代民主政治的理念未盡相符¹⁰⁵，在將來臺灣制憲時自不應採納。相反地，除了選舉之外，保留原住民族以及性別名額保障的設計就會更為重要，性別比例或許應要求任一性別的制憲委員不得低於三分之一，而原住民族在數量上由於人口比例的關係，無論如何都會是極少數，或許可以考慮的是給予這些代表在涉及原住民族事項時的否決權。

四、制憲原則

在草擬憲法過程中，有兩個特點需要注意，第一個是臺灣是在

102 Helen Irving, *Drafting, Design and Gender*, in *COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW* 19, 19 (Tom Ginsburg & Rosalind Dixon eds., 2011).

103 郎裕憲、陳文俊（註87），頁238-293。

104 陳昭如，改寫男人的憲法：從平等條款、婦女憲章到釋憲運動的婦運憲法動員，*政治科學論叢*，52期，頁54-60（2012年）。

105 孫宏雲，區域代表或職業代表？——國民黨對職業代表制的理解和運用，收於：深町英夫編，*中國議會百年史：誰代表誰？如何代表？*，頁102（2019年）。

民主化已經相對成熟的時候進行這項憲政工程，而不是在威權轉型的過程中，這代表憲政文化已經相對深入人心，而政黨實力的分布更為明朗，這些特點將會使未來制憲時應更重視某些原則，例如更公開的群眾參與、更明確的憲法制定程序規範、甚至是司法權的介入¹⁰⁶。第二個則是臺灣內部對於國家認同的歧異，研究指出在這種因為國家認同而高度對立的社會中制憲，更需要格外注意某些原則，例如漸進式的制憲與非單純多數決的議決方式。具體來說，目前對於制憲時所應注意的原則，主要包括過程的公開性¹⁰⁷、文本的可塑性／特定性¹⁰⁸、以及內容的漸進原則¹⁰⁹。當然，臺灣是否適用這些比較憲法上所發展出來的原則，相當程度上還必須參考自己過去的制憲經驗。最後，真正困難的問題並不是要不要遵循這些原則，而是這些原則落實到極致的話，彼此常常有衝突之處，也就是說，我們必須在不同的原則之間取得平衡。

（一）公開性原則

公開性原則所討論的，是憲法草案的撰擬與討論的過程，以及個別委員的投票結果，是否、以及在什麼程度上要公開的問題。由於公開討論過程有助於讓國民知道委員的立場以及所持理由，因此可以達到四個目的。首先，公開討論或許可以促進審議思辨，因為公開使得所有提案都能被攤在陽光下，想要說服別人支持自己的提案，就必須提出更有說服力的論據，而非仰賴利益交換；其次，公開討論也有助於全民的監督，防止自利行為，這裡指的防止自利行為有兩個層次，在個人的層次，公開討論過程有助於讓大家判斷委員所提的建議，是否係出於自身的利益考量，包括現在的利益或在

106 Gabriel L. Negretto, *New Constitutions in Democratic Regimes*, in REDRAFTING CONSTITUTIONS IN DEMOCRATIC REGIMES: THEORETICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVES 1, 26 (Gabriel L. Negretto ed., 2020).

107 ARATO, *supra* note 59, at 11, 101-04; VERMEULE, *supra* note 49, at 10-11.

108 ELKINS ET AL., *supra* note 11, at 78-88.

109 HANNA LERNER, MAKING CONSTITUTIONS IN DEEPLY DIVIDED SOCIETIES 40-46 (2011).

將來憲法草案通過後的可預見利益；其次，利益也未必是一身專屬，而有可能是所屬機構、甚至所屬政黨的利益，舉例來說，如果委員曾任職於立法機關或行政機關，則有可能會在憲法草案中強化立法部門或行政部門的權力，進而危及權力分立。再者，公開制憲過程或許有助於一般大眾得以透過媒體，對憲法草案的內容更為熟悉，進而有更充分的資訊決定是否批准憲法草案。最後，某些國家的制憲經驗顯示制憲者開誠布公地討論彼此之間的歧異，在資訊對等的情況下，有助於降低猜忌與促進族群融合，最終導致成功制定憲法¹¹⁰。也因此，有論者認為制憲過程——不論是憲法委員會的集會、草擬憲法內容或投票結果——必須越公開越好¹¹¹。

然而，公開性原則也必須受到一些節制，許多研究指出，正如同法官評議不會公開一樣，完全公開制憲討論過程可能會影響討論的品質¹¹²，因此我們有必要考慮不同程度的公開，究竟是所有討論過程都要全程公開、還是公開個別委員的投票結果、抑或只公開最後每個憲法條文草案各自獲得多少票¹¹³。如果將所有討論過程公開，將可能導致委員無法暢所欲言，因為他們可能會擔心往後被質疑立場前後不一，而無法大膽提出所有的可能性¹¹⁴；另一種可能是委員可能擔心對不起自己所代表的族群，而無法充分考量不同立場；再者，全程公開雖然使全民得以監督、參與討論過程，但這也意味著利益團體得以更精準地遊說特定委員，甚至是「固票」，進而可能左右制憲結果¹¹⁵。從這個角度看來，個別委員的投票結果，似乎也不應該公開，除了避免為利益團體所掌握之外，也可以降低

110 David C. Williams, *Constitutionalism before Constitutions: Burma's Struggle to Build a New Order*, 87 TEX. L. REV. 1657, 1691-92 (2009).

111 COLÓN-RÍOS, *supra* note 82, at 160.

112 ARATO, *supra* note 59, at 101.

113 關於投票與辯論（非限於制憲場合）應否公開或保持秘密的一般性討論，參閱JON ELSTER ED., *SECRECY AND PUBLICITY IN VOTES AND DEBATES* (2015).

114 Elster, *supra* note 40, at 388; Elster, *supra* note 96, at 27.

115 VERMEULE, *supra* note 49, at 11.

政黨對所屬黨員的操控，並稍微降低制憲委員之間私下進行利益或提案交換（log-rolling）的情況¹¹⁶。而且從防弊的角度來看，人民仍有最終批准憲法草案與否的權力，因此對於討論過程的公開性要求，似乎可以略為降低¹¹⁷。最後，討論過程不公開，可以避免某些委員試圖爭取媒體目光，嘩眾取寵，把制憲當作是累積個人政治資本的場合¹¹⁸，也因此，學者便提出所謂沙漏式（hourglass）的制憲過程，也就是一般人民在制憲的前端（選舉制憲委員）與後端（批准制憲草案）控制制憲結果，但中間討論過程則在一定程度保密的情況下進行¹¹⁹，現行的西班牙憲法，在當年制憲的過程中就很類似這種模式¹²⁰。

在這點上，中華民國憲法制定過程，可謂幾乎完全不公開。五五憲草還在訓政時期，草案的撰擬幾由國民黨一手包辦，而政治協商會議則是很典型的政黨菁英間的協商，甚至政治協商會議後的政協憲草，還是由雷震在獲得國、共兩黨同意後，私下去商請張君勱草擬¹²¹，一般民眾根本毫不知情，更遑論有置喙的餘地。考量到當

116 Elster, *supra* note 90, at 168.

117 甚至有認為只要保留人民最後擁有否決權，則在制憲過程時採取菁英主義，並不必然缺乏民主正當性。而且制憲的成敗與否，也不繫於過程有多開放，而更大程度取決於這些制憲菁英的個人品格。András Sajó, 論制憲與修憲，收於：葉俊榮、張文貞編，*新興民主的憲政改造*，頁88-89（2008年）。

118 See Elster, *supra* note 96.

119 See Elster, *supra* note 40.

120 Richard Gunther, *Constitutional Change in Contemporary Spain*, in *THE POLITICS OF CONSTITUTIONAL CHANGE IN INDUSTRIAL NATIONS: REDESIGNING THE STATE* 42, 53 (Keith G. Banting & Richard Simeon eds., 1985).

121 張君勱本人既非國民黨也非共產黨，當時是隸屬中國民主同盟。隸屬小黨這件事情，事實上反而成為他雀屏中選的其中一個理由，因為當時在政治協商會議後、參與制憲委員會的成員，本來推舉包括孫科、王寵惠、周恩來、吳經熊、張君勱在內的七個人撰擬憲法草案，但由於國共兩黨互不信任，且政治協商會議的結論對於憲法草案的想像，與國民黨偏好的五五憲草版本歧異甚大，這使得王寵惠與吳經熊兩位隸屬國民黨的法學大家，均不願擔當草擬的工作，因此隸屬小黨、又對比較憲法與憲政理論有所研究的張，反而成為兩黨都可以接受的人選，這也使得張君勱幾乎是一手撰擬了現行中華民國憲法的草案。該草案出爐後，共產黨與其餘小黨均表歡迎，但卻一度引起國民

時中國的政治、社會情況，加上民眾識字率偏低，這或許難以苛責當時的政治菁英。但今日的臺灣已經截然不同，要考量的反而是上述太過公開會導致的流弊。因此，本文認為，憲法草案協商過程固然應予公開，以供民眾檢驗，但個別委員的投票結果，則可能須視制憲委員會的組成方式區分。如果在制憲委員會組成的階段，是採取第二種模式，也就是由立法委員擔任制憲委員的話，則比照司法院釋字第499號解釋的看法，似乎應當公開個別委員的投票結果，以免其「對選區選民或所屬政黨所負政治責任……無從貫徹。¹²²」雖然大法官解釋是針對修憲而非針對制憲，然而本文認為應使制／修憲委員，針對制／修憲結果對人民負責這點，並無差異。但如果是採取第一種模式，也就是重新選舉制憲委員的話，則個別委員的投票似可考慮予以保密，以免渠等受到不必要的壓力與影響，其理由在於這種模式下的制憲委員並不一定具有政黨屬性，而可能是社會專業公正人士，且渠等在制憲結束後就解散，似較無政治課責的可能性。既然如此，則不如藉由不公開其投票結果，來防止其受到不必要的壓力。至於希望原本透過政治課責拘束制憲委員不要恣意行事或謀求私利的目的，則由人民對於制憲草案的最終否決權來加以確保。

（二）可塑性與明確性

憲法制定的過程中，制憲者應隨時注意保持憲法草案的可塑性（flexibility），使用的文字必須適度的保持開放，這一方面能避免過

黨的反彈，最終仍在1946年11月送進立法院，並在王寵惠、吳經熊與雷震的小幅度形式調整下，送進了制憲國民大會。由於後來共產黨拒絕出席制憲國民大會，張君勱的草案版本，雖然相當程度上偏離了依循孫中山遺教、且為國民黨所偏好的五五憲草版本，但在國民黨試圖維持制憲國民大會是多黨派參與、而非國民黨一黨獨斷的考量下，張君勱的版本在小幅度修正後便通過成為目前的中華民國憲法。雷震（註94），頁105-109；李炳南，政治協商會議與國共談判，頁325-327（1993年）。

¹²² 司法院釋字第499號解釋。

於僵化的憲法草案，無法應付往後的政治經濟局勢變更，進而使耗費巨大政治社會成本所制定的新憲法，在通過不久後，隨即面臨必須再行修正的窘境。這也是為什麼世界各國憲法的基本權利清單，不但用語多半簡單扼要，更經常保留概括條款的原因。這種情形常常發生在制憲者認為決策成本過高，或是一旦決策錯誤導致的結果相當嚴重的情形¹²³，前者通常發生於制憲者對特定爭議無法凝聚共識，而僵持不下；後者通常是囿於時間因素或人的智識有其極限，而使制憲者的資訊不夠充分。在這兩種情形下，制憲者應該要儘量保持憲法文本的開放性或是文字的可塑性，以利後續的憲法變遷。而且這麼一來，相對抽象而空泛的憲法文本可能也比較能凝聚制憲委員的共識，並保留給後代不同解讀的空間，避免在制憲過程遭遇瓶頸，而使得憲法草案難產。而除了用語刻意模糊之外，另一種保留可塑性的方法，則是透過憲法委託，交給未來的立法者來決定¹²⁴，這經常發生在權利清單中。

現行中華民國憲法第4條規定中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。事實上在制憲國民大會中，曾一度討論是否回復五五憲草所規定的列舉式用語¹²⁵，也就是將當時中華民國領有的各省逐一表列在憲法第4條中，這在世界各國的憲法設計上是非常少見的例子¹²⁶。後來是因為孫科以臺灣和蒙古為例，前者於1945年收回（故五五憲草其實並未將臺灣省列入），而後者則於1921年獨立，藉此說明列舉式的弊病；此外，並

123 Rosalind Dixon & Tom Ginsburg, *Deciding not to Decide: Deferral in Constitutional Design*, 9 INT'L J. CONST. L. 636, 641-46 (2011).

124 *Id.* at 636.

125 五五憲草的該條規定是：中華民國領土為江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、西康、河北、山東、山西、河南、陝西、甘肅、青海、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、熱河、察哈爾、綏遠、寧夏、新疆、蒙古、西藏等固有之疆域。

126 Oran Doyle, *The Silent Constitution of Territory*, 16 INT'L J. CONST. L. 887, 890 (2018).

有制憲國代指出香港和澳門尚未收回¹²⁷，若採取列舉式的體例，將來還必須另行修憲，因此才維持了現在的條文用語。至於憲法委託，則像是憲法第8條的「非經司法或警察機關依法定程序」以及第23條「不得以法律限制之。」都是當年制憲者藉以保留憲法彈性的例子。

當然，憲法的可塑性必須有其限度，否則將會失去之所以制定剛性成文憲法的意義，因此，憲法草案的文字並不是越開放越好，作為成文憲法，明確性也是一個制定憲法時應注意的原則，理由在於明確的憲法文字有助於凝聚共識、避免爭議，一旦有人違反這些規定，人們很容易察覺、並進而一同反對違憲的行為，發揮協調的功能。而且由於違反明確憲法規定的行為過於明顯，也有助於事先嚇阻這類的企圖，兩者皆能提高憲法被遵守的可能性，進而促進憲法的穩定性¹²⁸，最好的例子就像是總統任期長短以及連任的限制。

進一步地說，明確性可以表現在兩個方面：憲法所規範的議題多寡（例如明白承認多少種類型的基本人權）以及個別規範的仔細程度（例如我國憲法第8條）。由於制憲者的時間通常有限，這兩種意義的明確性，有時將彼此衝突，因為一旦憲法規範的範圍越寬廣，則個別憲法條文可能就無法非常精細。因此究竟要多明確、在什麼方面明確，往往受幾個因素影響，像是該國的憲政文化是否成熟、該國的人口組成是否多元、制憲者彼此協調溝通的成本、以及政局的穩定與否¹²⁹。通常，如果憲政文化越成熟、人口組成越多元、特定議題的溝通成本越高、以及政局越穩定，那麼制憲時儘可能的保留可塑性可能比較好。此外，研究顯示，制憲者人數越多，

127 國民大會秘書處編，國民大會實錄，頁1215（1946年）。

128 Barry R. Weingast, *The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law*, 91 AM. POL. SCI. REV. 245, 261 (1997).

129 Tom Ginsburg, *Constitutional Specificity, Unwritten Understandings and Constitutional Agreement*, in CONSTITUTIONAL TOPOGRAPHY: VALUES AND CONSTITUTIONS 69, 84-86 (András Sajó & Renáta Uitz eds., 2010).

往往可能造成憲法草案在範圍部分越明確¹³⁰，這理由不難理解，由於制憲者背後通常均代表著特定的團體、利益或意見，因此會希望在制憲會議中，將其所代表的立場入憲；這雖然一方面使得對新憲法的施行，有利害關係的族群變多，而使得新憲法更容易受支持，但另一方面來說，由於新憲法承諾的事情太多，將反而可能導致在施行後無法完全做到，進而長久下來反不利於憲法的有效性。當然，保留可塑性的風險之一就是政治部門可能同樣囿於決策成本與錯誤成本的限制，而根本不會處理該議題，進而使得憲政發展一直停滯不前。

因此，不僅明確性原則會和可塑性原則有所衝突，兩個層面的明確性原則本身也有緊張關係。但不論是哪種意義的明確性，越明確的憲法草案意味著保留給司法部門的解釋空間越小¹³¹。換句話說，如果制憲者對於司法解釋越沒有信心，或是該國沒有司法解釋的傳統，似應在可塑性與明確性之間，更倚重後者；相反地，如果司法解釋歷史悠久，且廣獲人民支持，則似可在撰擬憲法草案時，更著重可塑性一些。另外一種可能的作法是，在基本權利的部分更重視可塑性，而在權力分立的領域則偏重明確性原則，其理由在於權利的概念往往更需要與時俱進，而科技日新月異的發展，不但使政府侵害人民權利的手段更細緻幽微，更常常影響權利的面貌，因此想要在制憲之初就明確規範何種權利應予保障、如何保障，往往是天方夜譚。相對地，在權力分立的場域，由於涉及不同部門之間的權力劃分，如果規範不夠明確，當政治部門由不同政黨所掌握時，則部門之間容易有所衝突，進一步造成政治動盪或政治僵局。即便有司法權的介入，也往往容易造成法院與其他部門的對抗，這除了傷害司法獨立之外，長久下來也不利憲政發展。至於如何根據

130 Rosalind Dixon, *Constitutional Drafting and Distrust*, 13 INT'L J. CONST. L. 819, 825 (2015); Blount et al., *supra* note 84, at 50.

131 Dixon, *supra* note 130, at 820.

上述這些判斷標準，在不同條文之間，折衷可塑性與明確性原則，便成了制憲者討論時的重要議題。

以世界各國的憲法來看，現行的中華民國憲法其實是相對不明確的，不但明文承認的基本權利類型數目很少¹³²，就連憲法的長度，在世界各國的憲法中也很短¹³³。當然，這未必是壞事，明確與否與憲法是否能落實，兩者是不同的議題，彼此並無一定的關聯，但如果憲法規定得越不明確，其結果就是必須更仰賴其他有權機關的解釋。司法院大法官能在臺灣的政治場域扮演這麼重要的角色，或許先天上的緣由部分在此，而這種決定本身無關好壞，就只是一種憲法政策的選擇。至於在未來制憲時，本文也認為在權力分立領域應該偏重明確性，以避免過去臺灣憲政發展上的諸多問題，像是總統與行政院長的互動，或是立法調查權限等爭議。至於在人權領域，除了可考慮增加已透過解釋明文承認的權利類型外，仍應保持一定的彈性，像是維持概括條款。

（三）漸進原則

除了上述應注意的一般性原則之外，研究指出在國家認同有高度對立的社會中，制憲還必須採取漸進式的改良主義，避免企圖一次解決有高度爭議的議題，否則縱使依賴人數上的多數逕行將沒有共識的政治決議入憲，也只是埋下往後憲法變遷、甚至政治動亂的種子而已。所謂漸進式的憲法變遷，是指避免使用多數決、忠實呈現意識形態的差別、將爭議問題的答案留給未來的政治部門而非憲法來解決¹³⁴。這種做法的好處是對於現在沒有共識的問題，與其在

132 *Constitution Rankings*, COMPARATIVE CONSTITUTIONS PROJECT, <https://comparativeconstitutionsproject.org/ccp-rankings/> (last visited Feb. 13, 2022).

133 平均約為14,000字，ELKINS ET AL., *supra* note 11, at 105. 中華民國憲法11,000字左右。當然，長度本身僅能作為一個粗略的指標，無法精確反映出明確程度。

134 LERNER, *supra* note 109, at 39-46; Roberto Gargarella, *Constitution Making in the Context of Plural Societies: The "Accumulation Strategy"*, in CONSTITUENT ASSEMBLIES 13, 17-19 (Jon Elster et al. eds., 2018).

制憲委員會中因產生僵局而使整個制憲的計畫宣告失敗，不如先處理比較有共識的部分，並承認有這一代的人民所無法解決的問題。

不過這麼做並不是沒有風險，把問題放著不處理，就像皮膚上的傷口一樣，有些會自然痊癒，有些則會化膿導致更嚴重的後果。美國制憲時同樣因制憲者彼此意見不一，而決定不根本地處理蓄奴問題，其結果就是數十年後歧見沒有縮小反而日益擴大，最終仍無法避免透過內戰來解決¹³⁵。同樣地，漸進式制憲的問題也發生在伊拉克，當時的制憲者刻意將部分涉及政府組織的爭議留待後續的修憲或立法來解決，不幸的是後面的執政者到現在還沒彌補這些空白。這暴露出漸進式制憲的另一個缺點：漸進主義要成功，前提是在歷史上被邊緣的少數族群有足夠的話語權，否則將重大憲政問題置之不理，實質上就是延續既有的制度安排，一旦憲法公布後立法怠惰，長久下來基於路徑依賴的慣性，將會使得往後要推行憲改更加困難¹³⁶，這也是尼泊爾在2015年制憲時，少數派堅持拒絕採取漸進主義的理由¹³⁷。因此，有學者指出制定一部憲法本身不是最終目的，重點是制定一部會被長久遵守的憲法，以鞏固往後的憲政發展，而藉由擱置重要問題所通過的憲法，只是將問題往後延。因此漸進主義最好當作一種在制憲過程中，逐步透過審議、妥協，在制憲期限內達成合意的手段，而不能成為制憲者最終逃避決策的藉口¹³⁸。

這兩種說法在理論上都言之成理，然而以阿富汗的經驗來看，兩者都沒辦法真正解決問題：漸進式制憲固然使得阿富汗制定了憲法，但國內的問題卻日趨嚴重¹³⁹。同樣地，歷史不能重來，我們不

135 Gargarella, *supra* note 134, at 17.

136 Rosalind Dixon, *Constitutional Design Deferred*, in *COMPARATIVE CONSTITUTION MAKING* 165, 174-75 (David Landau & Hanna Lerner eds., 2019).

137 Mara Malagodi, *The Rejection of Constitutional Incrementalism in Nepal's Federalisation*, 46 *FED. L. REV.* 521 (2018).

138 HOROWITZ, *supra* note 13, at 112.

139 Clark B. Lombardi & Shamshad Pasarlay, *Constitution-Making for Divided Societies: Afghanistan*, in *CONSTITUTIONALISM IN CONTEXT* 89, 112 (David S. Law ed., 2022).

知道當年如果美國制憲者堅持處理奴隸制度存廢問題，到底還會不會有美國憲法的誕生。換句話說，真正困難的是，我們不知道現在的歧異，如果不處理的話，究竟會把國家帶往何處。然而即便如此，有些議題在當下就是無法解決，甚至可能連使用模糊語句以保留可塑性的空間都沒有，在這種情況下，也就只能乾脆不處理。這種漸進式的制憲方式，本身毋寧只是一種務實或囿於情勢所逼的做法，與制憲之後的憲政發展情況，並不必然相關。

在中華民國憲法制定時，這種原則體現在一條目前已經被刪除的條文上，原本的憲法第7條並不是平等權的規定，而是規定中華民國的首都在南京¹⁴⁰。但該條草案在制憲國大中引起相當多爭議，而首都的地點也有所變化，除了當時國民黨控制的南京之外，連北平、武漢、西安也都曾被提出作為首都¹⁴¹，甚至到憲法草案一讀時，首都一度被改為北平。由於北平離中國共產黨控制的北方省分較近，蔣介石一度堅持以南京為首都，導致各省代表無法獲得共識。最終在僵持不下的情況下，各方妥協，遂於二讀中刪除本條。就這一點而言，後來政府遷臺後，教育部曾在2013年以公文指示各中小學，在教科書中應指明我國首都在南京，引起一陣風波，最終則以教育部道歉了事¹⁴²，實際上對臺灣的憲政發展，並無造成任何影響。從這個角度來看，當初擱置首都位置入憲的爭議，應是一個明智之舉。今日在臺灣，我們所面臨的是更嚴重的國家認同的問題，就此，如果屆時仍無足夠共識的話，漸進原則給我們的啟示，或許是在將來的新憲法中，先將國家認同擱置不談，採用類似「因應國家發展之需要，特制定本憲法」等中性字眼，但同時不細究中

140 該條規定原本是：「中華民國，國都定於南京。」參國民大會秘書處編（註127），頁620。

141 國民大會秘書處編（註127），頁866、1089、1112、1117、1121、1224、1243、1352。

142 政治中心，中華民國首都南京？教育部坦承太簡略「深感抱歉」，ETtoday新聞雲，2013年12月3日，<https://www.ettoday.net/news/20131203/303504.htm>（最後瀏覽日：2023年4月1日）。

華民國未來的方向究竟是與中國統一、還是成為以臺灣為名的獨立國家、抑或者是其他可能性。保留一個文字的模糊性作為交疊共識的基礎，讓下一代的臺灣人去處理，未必不是一個好的做法。

五、制憲工程與司法審查

傳統憲法理論認為司法違憲審查負責解釋憲法，至多得以審查憲法修正條文是否違反既存的憲政框架，但要從混亂中重新塑造憲政秩序則不適合交給法院¹⁴³。除了這種概念上的局限之外，在現實上，法院是屬於舊憲政秩序的一環，如果舊憲政秩序出了問題，那麼法院可能正是問題的一部分，也就是要被改革的對象，在這種情況下，還賦予法院審查新憲法草案的職責，毋寧是本末倒置。

即便如此，有越來越多的國家容許憲法法院在制憲過程中扮演一定的角色，包括冰島、東歐和拉丁美洲國家、與最知名的南非¹⁴⁴。這部分取決於制憲是由什麼契機所引發，部分則取決於法院本身的正當性與權威性。而所謂扮演一定的角色，還可以進一步依法院所介入的領域區分為形式或實質監督，以及依介入時間來區分是草案提出前還是提出之後¹⁴⁵。詳言之，法院有可能在草案提出前，就針對程序事項進行監督，例如制憲提案是否符合相關法規範。如上所述，很少憲法會規定新憲法的制定程序，即使有，往往也不夠明確或詳細。因此制憲會議的召開，本身有時候會引起爭議，像是總統是否有權獨自召開制憲會議重新制憲？這在一些中南美洲國家，像是哥倫比亞或委內瑞拉，常常會引起總統濫權的疑慮，而需要法院介入審查¹⁴⁶。換句話說，法院在制憲過程中，最有正當性的場合，

143 ACKERMAN, *supra* note 61, at 99-112.

144 ANDREW ARATO, THE ADVENTURES OF THE CONSTITUENT POWER: BEYOND REVOLUTIONS? 186 (2017); COLÓN-RÍOS, *supra* note 51, at 289-93.

145 David Landau & Rosalind Dixon, *Constraining Constitutional Change*, 50 WAKE FOREST L. REV. 859, 876-88 (2015).

146 COLÓN-RÍOS, *supra* note 51, at 251-59.

可能是在確保制憲委員會的組成，符合相關程序性規範，例如是否有一定的性別代表或少數族群保障名額，以確保修憲程序中，沒有缺少特定族群的聲音¹⁴⁷。除此之外，草案提出後，法院可能就相關程序事項進行審查，例如表決過程與表決方式是否合法、票數計算是否正確……等等，這些都是相對沒有正當性爭議的情況。

至於草案提出後，法院是否適合實質審查草案內容，則有相當之爭議。傳統上認為制憲權的行使，不應受司法審查的實質拘束。然而，南非在結束種族隔離後、制定新憲前，先在1994年頒布了臨時憲法，其中規定了必須被新憲法所囊括在內的34條原則。在1996年南非政府第一次提出憲法草案時，由於該草案與前述34條原則未盡相符，因此南非憲法法院便以此為由退回該草案，南非政府只好再提出一個新的憲法草案，最終才獲得憲法法院的許可¹⁴⁸。這在比較憲法上是一個法院實質審查憲法草案內容的極少數例子。實務上另外一種情況是，由於制憲草案的公布與通過，中間經常還有一段時間上的落差，因此政治勢力的洗牌有可能導致先前憲法草案的內容，已經不再為新上臺的政權所認同，那麼新政權是否會甘願受舊政權所通過的憲法草案所拘束，有時就會產生爭議。在這種情況下，新政權刻意使法院取得實質審查的權力，並透過新法院進行訴訟，就變成一種權力鬥爭的手段¹⁴⁹。

本文認為應當容許司法院大法官審查制憲過程是否符合相關程序性規範，至於這是否會涉及司法院大法官的利益衝突，則牽涉到

147 David Landau, *Courts and Constitution Making in Democratic Regimes: A Contextual Approach*, in REDRAFTING CONSTITUTIONS IN DEMOCRATIC REGIMES: THEORETICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVES 78, 84 (Gabriel L. Negretto ed., 2020).

148 Claude Klein & András Sajó, *Constitution-Making: Process and Substance*, in THE OXFORD HANDBOOK OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 419, 436-37 (Michel Rosenfeld & András Sajó eds., 2012); ARATO, *supra* note 144, at 233-56.

149 Landau, *supra* note 147, at 91.

審查的範圍是否及於草案實質內容。就此，本文認為憲法草案的實質內容，縱使具有高度爭議，或甚至違反目前臺灣民眾熟悉的憲政秩序，應不在法院得審查的範疇，因此不會使憲法法院產生利益衝突的問題。

肆、公眾參與

所謂公眾參與，依其對憲法草案內容的影響，又可以分為直接參與和間接參與，前者例如公投批准憲法或提出憲法草案，後者則以選舉制憲委員為主。不論是哪種形式，在新憲法制定的過程中，如果越多民眾參與的話，在制憲通過後的憲政秩序將會更具有民主正當性且更穩定¹⁵⁰。詳言之，民眾在制憲的過程中的參與——包括但不限於最終的批准——縱使沒有直接促進他們對於憲法的認同感，也可以加深他們對新憲法的理解¹⁵¹。而基於這些理解，他們會更有能力與意願監督政府的行為是否違反新憲法，這不但使得政府比較不敢公然違憲，而得以穩定憲政秩序，更能進而促進市民憲政主義發展，而間接地提高對新憲法的認同。

當然，高度的民眾參與，如果過於激情而失去理性的話，反而有可能妨礙憲法制定過程順利進行，甚而威脅憲政秩序的穩定¹⁵²。

¹⁵⁰ See John M. Carey, *Does It Matter How a Constitution Is Created?*, in *IS DEMOCRACY EXPORTABLE?* 155, 175-76 (Zoltan Barany & Robert G. Moser eds., 2009); Todd A. Eisenstadt et al., *When Talk Trumps Text: The Democratizing Effects of Deliberation during Constitution-Making, 1974-2011*, 109 *AM. POL. SCI. REV.* 592 (2015); Stefan Voigt, *The Consequences of Popular Participation in Constitutional Choice—Towards a Comparative Analysis*, in *DELIBERATION AND DECISION: ECONOMICS, CONSTITUTIONAL THEORY AND DELIBERATIVE DEMOCRACY* 199, 220 (Anne van Aaken et al. eds., 2004).

¹⁵¹ DEVRA C. MOEHLER, *DISTRUSTING DEMOCRATS: OUTCOMES OF PARTICIPATORY CONSTITUTION MAKING* 179 (2008).

¹⁵² David Landau, *Constitution-Making Gone Wrong*, 64 *ALA. L. REV.* 923, 926 (2013).

此外，有認為透過人民選舉產生制憲委員會，將使政黨實力提早掀牌，反而無助於真正在討論憲法草案時的協商¹⁵³。最後，在制憲之前的選舉激情，可能加深既有的對立，例如伊拉克與東帝汶的憲法制定過程便是如此¹⁵⁴。上述這些批評雖然不是無的放矢，但主要起源於尚未成熟的市民社會與選舉文化，而不能歸責人民參與本身。不過，在這些批評之外，也有研究指出光是民眾的參與本身並不能顯著影響憲法的成效，而必須仰賴政治菁英的合作¹⁵⁵，冰島在2010年到2013年間的制憲（失敗）經驗，是一個在憲法制定上，相當經典的案例。

當時冰島由於2008年的全球金融風暴，以及國內對於政府的不滿，因此發起了制憲。這次制憲在比較憲法上，幾乎可以說民眾參與程度最高的制憲典範。在經過高度的民眾參與和諮詢性制憲公投批准之後¹⁵⁶，冰島政府最終沒有採納公投結果。對於這樣一部曾經被高度頌揚為典範轉移的制憲過程，最後竟然落得制憲失敗的尷尬結果。除了審閱期間拖延太久、反對黨的抵制、政黨勢力的改變之外，有論者認為本次制憲高度仰賴政治素人，而與政治菁英脫鉤，不但使得政治菁英對制憲逐漸冷感，憲法草案本身的品質也有待加強¹⁵⁷。這個例子不但呼應了先前所說，制憲必須仰賴政治與法律菁

153 Justin Blount, *Participation in Constitutional Design*, in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 38, 43 (Tom Ginsburg & Rosalind Dixon eds., 2011).

154 Yash Ghai & Guido Galli, *Constitution-building Processes and Democratization: Lessons Learned*, in DEMOCRACY, CONFLICT AND HUMAN SECURITY: FURTHER READINGS 232, 237 (International IDEA ed., 2006).

155 Gabriel L. Negretto, *Replacing Constitutions in Democratic Regimes: Elite Cooperation and Citizen Participation*, in REDRAFTING CONSTITUTIONS IN DEMOCRATIC REGIMES: THEORETICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVES 101, 124 (Gabriel L. Negretto ed., 2020).

156 Anne Meuwese, *Popular Constitution-Making: The Case of Iceland*, in SOCIAL AND POLITICAL FOUNDATIONS OF CONSTITUTIONS 469, 476-89 (Denis J. Galligan & Mila Versteeg eds., 2013).

157 Björg Thorarensen, *Why the Making of a Crowd-Sourced Constitution in Iceland Failed*, INT'L ASS'N CONST. L. (Feb. 26, 2014), <https://www.constitutional-change.com/why-the-making-of-a-crowd-sourced-constitution-in-iceland-failed/>.

英和市民社會的合作之外，似乎也證明了民眾參與的程度並不一定是越高越好。不過，不論民眾參與的實際成效如何，在民主國家已經難以想像一部憲法的通過完全沒有民眾的參與，所差別者僅在於民眾參與的階段以及參與的程度。

在制憲前期，民眾多半以間接參與為主，也就是選舉制憲委員。由於制憲委員將大致決定憲法草案的內容，為了避免政治菁英透過制憲將既得利益入憲，將制憲委員交由民眾選舉產生，已經成為主流。研究顯示在1987年之後所制定的新憲法中，有65%的制憲，其制憲委員是透過民眾直選產生，而僅有12%的制憲，其委員是由行政部門所指派，剩下的則是由戰勝方任命、間接選舉、以及其他混合程序所產生¹⁵⁸。

至於在制憲中期，也就是草案的形成過程中，民眾參與的形式則包括直接參與和間接參與。後者像是最簡單的提供諮詢，前者則包括評論已公開但尚未定案的憲法草案，以及主動提出自己的憲法草案版本¹⁵⁹。對於這些建議，有一些國家會要求制憲委員會必須適當的回應，但大多數情況制憲委員通常沒有任何義務，對其也不產生拘束力。考量到這些建議或民間草案可能數量龐大，現實上也無從要求制憲委員另花時間去蕪存菁，因此多數國家的制憲經驗是讓這階段的民眾參與維持單純建議性質。值得注意的是，即使沒有形式上的拘束力，這些建議仍可能發揮實質影響力，例如蒙古在2019年修憲前，便隨機選取民眾代表與專家和政治領袖進行審議討論，藉此使民眾得以更直接的影響決策者，最終並確實影響了憲法修正案的內容¹⁶⁰。雖然該次審議不是針對本文所討論的制憲，但其進行模式並不因制憲或修憲而有本質上的差別。

158 Jennifer Widner, *Constitution Writing in Post-Conflict Settings: An Overview*, 49 WM. & MARY L. REV. 1513, 1522-23 (2008).

159 Blount, *supra* note 153, at 47-49.

160 Amarzaya Naran, *Insights for Design of Direct Public Participation: Mongolia as a*

最後則是影響制憲成敗最關鍵的批准階段，憲法草案在最後階段交由公民投票已經逐漸變成國際趨勢¹⁶¹，這不令人意外，畢竟公民投票象徵了人民當家作主、自我治理的價值¹⁶²。然而，部分研究指出，在民主制度尚未成熟的國家，像是俄羅斯、哈薩克、委內瑞拉，訴諸公投可能會導致獨裁者操縱公投，為個人專政披上民主的外衣，藉以避免國內抗爭與國際制裁¹⁶³。即便是在民主國家，從審議民主的角度來看，公投可能忽略了議題的複雜性，強迫人民必須在兩個選項中擇一，最終淪為多數暴力。因此，是否採取全民公投，與一國政府體制是否民主並無必然關聯。即使在民主轉型的脈絡下，也有部分國家採取由國會通過而非交由全民公投，像是1992年的捷克¹⁶⁴。

不過即便有這些批評，一般仍認為如果制憲者知道最後階段將採取公投的方式來批准，那麼在制憲的過程中，更容易將民眾的偏好入憲¹⁶⁵，從這個角度看來，相較於其他批准憲法草案的方式，公投最能彰顯一部憲法的民主正當性。在這個階段，主要考量的有兩點：考慮批准的時間長短以及批准的門檻高低。就前者而言，給一般民眾的審閱期間要多久，取決於制憲程序中公開的程度，以及草案本身的長短。如果在制憲程序中，討論越公開，則民眾越有可能及早知道草案的內容及其意義，那麼公布後所需時間自然越短。此

Case Study, Address at Fourth Melbourne Forum on Constitution Building in Asia and the Pacific (Oct. 21-22, 2019), https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/3224463/MF19-Mongoliaa-paper.pdf.

161 Blount et al., *supra* note 84, at 37.

162 賈文宇，公民投票的憲法功能與民主意義，台灣法學雜誌，410期，頁53-63（2021年）。

163 Partlett, *supra* note 74, at 210; David Landau, *The Importance of Constitution-Making*, 89 DENV. U. L. REV. 611, 629-30 (2012). 相反意見，STEPHEN TIERNEY, CONSTITUTIONAL REFERENDUMS: THE THEORY AND PRACTICE OF REPUBLICAN DELIBERATION 98-128 (2012).

164 Maxim Tomoszek, *The Czech Republic*, in HOW CONSTITUTIONS CHANGE: A COMPARATIVE STUDY 41, 41 (Dawn Oliver & Carlo Fusaro eds., 2013).

165 Voigt, *supra* note 150, at 218.

外，草案的長短則涉及上述所提及的兩種明確性，如果憲法草案所規範的範圍越廣，導致草案越長，民眾將會需要越多時間審視。此時如果草案公布後到公投的時間太短，民眾可能會無法好好消化草案內容，進而使同意與否成為單純政黨動員的結果，像是泰國的2007年憲法，草案共有300條，但軍政府只給泰國民眾19天的時間，這也引發同意票到底是同意憲法內容、還是出於恐懼軍政府的質疑¹⁶⁶。但如果民眾考慮時間太長的話，又怕憲改的動能逐漸消散，使得人民對於憲法草案的態度，受到在這段審閱期間的政治局勢所左右，進而使批准憲法與否，受到執政黨的執政表現影響。

如果臺灣未來要制憲，而且採取沿用修憲程序的途徑的話，在制憲前期，就沒有選舉制憲委員的問題，而將由立法委員提出制憲草案的工作，但在這過程中，或許立法院仍可考慮適度公布草案的進度與內容，以供民眾評論與建議，而在最後階段，憲法增修條文第12條也已經規定要交付公投，而現行中華民國憲法規定憲法修正案必須有6個月的審閱期間。如果採取其他途徑的話，那麼上述6個月的審閱期間仍可參考。在比較憲法上，關於制憲的這類規定更少，如果將視野擴大到憲法修正案的審閱期間，則許多憲法規範的審閱期間都介於60天到180天之間。因此，本文認為任何在這區間的審閱期間都可以接受，甚至不需要設定一個具體的時間，而是以區間的形式呈現，保留一定的彈性以考量其他因素，像是國定假日、下一次全國大選的時間點……等等，後者就涉及制憲公投是否綁大選的問題。

制憲公投是否必須和全國性大選同時舉行，本身是一個高度爭議的議題。支持方認為，公投綁大選的優點之一，在於可能節省行政成本，避免國家機器三不五時就要被動員起來協助處理大選業

166 VIRGINIA BERAMENDI ET AL., DIRECT DEMOCRACY: THE INTERNATIONAL IDEA HANDBOOK 52-53 (2008), <https://www.idea.int/publications/catalogue/direct-democracy-international-idea-handbook>.

務。此外，更重要的優點是能促進人民參與。所謂促進人民參與，在形式上，公投綁大選可能提高人民投票的意願；在實質上，人民對於制憲有可預期性，這可能提高制憲的程序理性，以及對於憲政議題審議思辨的廣度與深度¹⁶⁷。然而，反對者則主張，公投綁大選可能模糊焦點，使得對公投議題的態度受到對於執政表現的影響，降低理性討論憲法草案、對事不對人的空間。而且公投綁大選可能造成沉重的行政負擔，進而衍生各種亂象，影響公投的公信力¹⁶⁸。就此，本文不擬深入探討一般性公投的相關議題，但針對制憲公投而言，本文認為促進人民參與本身可能不是最重要的考量。由於制憲公投是一國憲法政治最重要的議題，可以想見的是主要政黨都會極力動員，如果在此前提下，人民還不會因為議題（也就是制憲）的重要性而參與，而必須仰賴公投綁大選的話，那也只表示制憲這件事情在人民心中還不是格外重要。因此本文認為，上述60天到180天的審閱期間內若適逢全國性大選，則合併舉辦亦無不可，但並無與下一次全國性大選掛鉤的必要性，以免使得審閱期間的設定，單純因為行政便利的因素而不必要地延長。

至於表決門檻的部分，單純多數決的門檻可能無助於保障弱勢族群，而且憲法所應具有的多元代表性不足，但過高的門檻則又造成少數暴力，賦予少數族群（未必是政治上弱勢族群）過高的否決權，進而違反人民主權原則（popular sovereignty）¹⁶⁹。中華民國憲法對此則付之闕如。比較憲法上有三種主要的模式，第一種是要求一定門檻的選舉權人的投票率，再依投票結果的單純多數決來看公

167 葉俊榮，週期修憲的程序理性，收於：葉俊榮、張文貞編，*新興民主的憲政改造*，頁21-23（2008年）（該文雖針對修憲週期，但就期間的討論，或可作為制憲時的參考）。

168 陳英鈴，十案公投綁大選——從比較法省思民主與法治的挑戰，*台灣法學雜誌*，380期，頁21-42（2019年）。更完整的分析，見陳英鈴，*公投法與政治*（2021年）。

169 Akhil Reed Amar, *The Consent of the Governed: Constitutional Amendment outside Article V*, 94 COLUM. L. REV. 457, 460 (1994).

投是否通過，這也是最普遍的一種門檻。以丹麥王國的憲法為例，其憲法要求要有四成的選舉權人投票，且在實際投票的人中過半¹⁷⁰。第二種則是不同層級的單純多數決，這通常發生在聯邦制國家，要求有過半的全國國民以及過半的邦／省／州的同意，像是澳洲或瑞士；第三種則是以實際投票人數為分母，要求超級多數決，這種超級多數決用在批准憲法的公投時例子相對較少，且通常發生在涉及國家主權或領土的議題時¹⁷¹。相對地，超級多數決比較常用在制憲委員會內部投票時¹⁷²。

那麼，如果未來臺灣要推動制憲公投，通過的門檻應該要是多少？如果在制憲途徑的部分，採取第二種途徑，那麼自然沿用現行修憲的門檻，也就是投票權人過半數人的同意。採取這個門檻的用意在於，寧可犧牲多數人（但尚未超過修憲門檻）的意願，也要透過超高門檻來確保政治的穩定，如此一來，也可以避免憲法淪為多數宰制的工具。因為一旦能通過門檻，則必然代表社會上絕大多數人都同意制憲，在這種情況下，縱然還是會有少數人反對，那也是沒有辦法的事情，因為在民主國家不可能追求一致決。考量到民粹主義在過去幾年間，在全球各地日漸盛行，透過超高門檻確保一時的政治多數，無法透過制憲將其政治利益入憲，或許也是值得考慮的做法。而且將制憲的門檻等同於修憲的門檻，可以避免一些對於新憲法正當性的質疑。畢竟制憲的目的之一在於凝聚、並彰顯全民對於國家認同的共識，如果共識不夠高的話，那麼將相當程度喪失制憲的意義。簡言之，以修憲門檻作為制憲門檻，這是一種最保守、但同時可能也是最穩健的做法。

170 Section 88 of the Constitutional Act of the Realm of Denmark: “If a majority of the persons taking part in the voting, and at least 40 per centum of the Electorate has voted in favor of the Bill as passed by the Folketing, and if the Bill receives the Royal Assent it shall form an integral part of the Constitution Act.”

171 TIERNEY, *supra* note 163, at 272-74.

172 Stephan Michel & Ignacio N. Cofone, *Majority Rules in Constitutional Referendums*, 70 KYKLOS 402, 404 (2017).

但如果不是採取第二種途徑，那麼就有進一步討論的必要。首先，公民投票法（下稱公投法）第29條規定公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。其次，現行修憲通過的門檻，則是以投票權人過半數人的同意為準，不論實際投票人數多少。當然，現行修憲以及公投法的規定，並不一定適合援用在批准憲法草案的公投上，我們或許可以在這兩者之間取得平衡。就此，首先要考量的是要以投票權人為基準還是以實際投票的人為基準，如果以投票權人過半的同意為批准憲法草案的標準的話，由於標準過高，這將反而導致不投票本身成為一種政治操作的武器，這從公民共和與審議民主的角度來看，都是有問題的¹⁷³，因為公投本身的意義就在於民眾直接參與（憲法）政治，如果一個公投門檻會導致民眾策略性的不參與，那毋寧與公投設計的目的相違背，而且將給少數群體過大的否決權。再者，以投票權人為基準，將使公投更容易被不當操弄，例如在投票時間、投票地點、投票方式、或投票日期這些形式要件上動手腳，提高投出有效票的難度。

反過來說，如果以實際投票人數為基準，考量到憲法畢竟是全國人民的代表，要維持一定的穩定性，必須得到絕大多數人的同意。如果要避免某一方趁一時的些微數量優勢，將仍未獲得絕大多數國民認同的議題入憲，扼殺往後辯論的空間，那麼要求實際投票人數的超級多數決，似乎並不是完全沒有道理。因此技術上來說，如果臺灣未來制憲不是採取沿用修憲程序的話，那麼制憲門檻似應在「實際投票人過半同意」的低標與「有投票權人的過半同意」的高標此兩者之間妥協，以實際投票人數的三分之二以上為通過門檻。誠然，三分之二這數字本身並沒有什麼魔力或必然性，因此這標準難免略嫌恣意，然而這似乎是一個避免多數暴力¹⁷⁴與少數暴力

¹⁷³ TIERNEY, *supra* note 163, at 277, 283.

¹⁷⁴ 關於民主決策究竟是否該採取單純多數決以及採取單純多數決的缺弊，相關

的折衷選項。不可諱言的是，不論是多數暴力或少數暴力，都可能使投票輸掉的族群對新憲法失去支持的熱忱，進而危及憲法的穩定性。因此，在訴諸任何投票表決之前，更重要的是制憲過程中的討論過程。學者因此指出，投票表決應當視為制憲過程中的最後手段，在這之前，制憲代表應當儘可能透過審議思辨進行說服，或起碼透過互相妥協來達成最大的交疊共識¹⁷⁵，真的沒辦法之後才交付投票。當然，一致決是幾乎不可能的事情，不過審議討論與妥協的過程，或許可以提高制憲代表的共識。而當一部憲法草案已經得到足夠多制憲代表的共識（sufficient consensus）時，只要這些制憲代表具有相當的人民代表性，那麼在草案訴諸公投表決時，即使是落敗的一方也比較有可能接受，這或許可以相當程度減低多數暴力的疑義，但不論採取什麼門檻，必然有某種程度的「多數暴力」，這是在所有非共識決的決策模式下，沒有辦法徹底解決的。

最後，制憲公投的結果必須要有拘束政府的效力。一般來說，由於制憲公投的民主正當性，即使其僅有建議性質，通常也會實質上拘束各國政府，像是英國脫歐公投。然而，如上所述，冰島在

文獻汗牛充棟。批評者多半會從實證面與規範面兩個角度，指出許多單純多數決的問題，例如一般民眾並非理性投票者、對於相關議題缺乏決策所需的興趣與知識……等等。然而單純多數決之所以還是目前世界上政治決策的主要標準，其原因在於這些批評固然有其道理，但不足以完全否定單純多數決的優點，而且許多弊病，可以（也已經）透過許多措施獲得緩和，例如在最終投票前，先進行審議思辨，以提高人民對相關議題的興趣與認識，並汰除不適當的選項。See HÉLÈNE LANDEMORE, *DEMOCRATIC REASON: POLITICS, COLLECTIVE INTELLIGENCE, AND THE RULE OF THE MANY* 145-207 (2013). 選舉或公投前的政見發表會或辯論，很重要的功能之一就在於此。換句話說，所謂採取單純多數決，並不是只要人民在投票日當天盲目的投票而已，在投票日之前，已經會採取許多措施，協助人民做出更正確的決定。同樣的道理，未來制憲時，可以想見的是在投票前，不論是朝野政黨或公民社會，不論是贊成或反對，應該也會透過許多演講、辯論和宣導，來促進大家對於新憲法草案的理解，在這個前提下，單純多數決的弊病，應當可以適度減輕。如果再進一步考量到這裡所建議的是三分之二的超級多數決，已經比單純多數決更為慎重，那麼應可兼顧對於少數的保障。畢竟，單純多數決並不必然等同於多數宰制。

¹⁷⁵ HOROWITZ, *supra* note 13, at 7-8.

2008年金融危機之後曾舉行制憲公投，最後並批准新憲法草案的內容，但冰島政府卻以該次公投僅有建議性質而忽略之¹⁷⁶。這在臺灣固然難以想像，但仍是一個應該小心處理的問題，以免耗費龐大成本所產生的制憲公投結果，不但沒有為一國的長治久安奠定基礎，反而成為下一場政治鬥爭的起點。

總而言之，擴大民眾參與不僅在規範層面或實踐層面，固然是制憲時很重要的一部分，然而制憲不僅僅是單純反映民眾偏好的一項工程，更涉及法律與政治工作層面，因此參與者仍應包含相當程度的實務工作者，以利制憲工作的推行。而過去幾年內在全球民粹主義的興起，更讓人意識到具有高度政治性的制憲工作，極可能成為煽動家操弄的對象，而憲法在一國法秩序的地位，讓這種風險實現的後果更難以承擔。因此我們固然要儘可能提高新憲法的民主正當性，另一方面則必須謹慎對待制憲過程中任何可能出錯的地方，從比較憲法的經驗看來，民眾高度參與制憲實際上是一把雙面刃，因此切勿帶著玫瑰色的眼鏡看待這件事。

伍、結論

除了分配政治權力、維繫政府運作之外，憲法還具有強烈的表意（expressivist）性質，能夠協助一群人民，透過憲法的社會整合功能，了解自己作為一個政治共同體，而成立一個國家¹⁷⁷。這個功能，在這群人缺少共同的宗教信仰、歷史記憶、或是國家認同時，特別重要。因此，不乏有憲法雖然具備形式上的權威性，在實踐上

¹⁷⁶ Thorvaldur Gylfason, *Chain of Legitimacy: Constitution Making in Iceland*, in CONSTITUENT ASSEMBLIES 161, 180-83 (Jon Elster et al. eds., 2018).

¹⁷⁷ Mark Tushnet, *The Possibilities of Comparative Constitutional Law*, 108 YALE L.J. 1225, 1228 (1999).

也普遍為人所遵守，但卻無力凝聚人民、形塑國家¹⁷⁸，中華民國憲法在臺灣的狀況就是如此，所有人民與政治、法律菁英（包括民進黨籍的總統與其所提名的法官），都必須遵守中華民國憲法，而這部憲法的絕大多數條文，事實上也有其實效性，但它卻無法成為國家認同的某種象徵，甚至反而深化了國家認同的歧異。從這個角度來看，未來臺灣制憲與建國是密不可分的。雖然現行的中華民國憲法在臺灣施行的情況並不十分糟糕，但以目前大多數臺灣人的國家認同來看，中華民國憲法作為臺灣這塊土地的最高法，無可避免地會使臺灣的國格（statehood），不論是在內國或是在國際上，產生一定程度的混亂與爭議¹⁷⁹，進而妨礙臺灣作為一個主權獨立的國家，這其實也是前國際法院法官James Crawford所說的「臺灣還不是一個國家，因為它還沒有主張自己已經從中國所分離」¹⁸⁰。從這個觀點來看，臺灣未來要被認為是一個國家，就必須主張它不是中國（的一部分）¹⁸¹，而制定一部新的臺灣憲法，就是做出這種主張其中一種最有力的形式。既有的修憲條文雖然在實質上是為了臺灣這塊土地所制定的，但修憲仍然不被認為是在主張臺灣是一個獨立的國家，因為在形式上，臺灣人民所修改的仍然是中華民國憲法，且所修的修憲條文，文本中仍然宣稱臺灣屬於中國的一部分（所謂的自由地區）¹⁸²。換句話說，雖然中華民國憲法在相當程度上已經「臺灣化」，但仍有其極限。倘若臺灣未來想要成為一個正常國家，

178 MARTIN LOUGHLIN, AGAINST CONSTITUTIONALISM 112-13 (2022).

179 相關爭議的不同見解，參閱許慶雄，中華民國與臺灣之地位——依國際法法理評析，律師雜誌，314期，頁14-25（2005年）；陳春生，台灣的國家定位，律師雜誌，314期，頁26-48（2005年）；陳荔彤，臺灣在國際上的地位分析，律師雜誌，314期，頁49-61（2005年）。

180 JAMES CRAWFORD, THE CREATION OF STATES IN INTERNATIONAL LAW 219 (2006) (stating that “The conclusion must be that Taiwan is not a State because it still has not unequivocally asserted its separation from China and is not recognized as a State distinct from China”).

181 *Id.* at 211.

182 *Id.* at 212-15.

似乎仍然必須制憲，只是制憲的手段與途徑，可以再進一步討論和妥協。一言以蔽之，制憲並不是單純的只是想迴避修憲門檻過高的問題，而是要進一步透過憲法變遷，對國際社會清楚地主張臺灣的國家定位。

正因制憲是未來無法迴避的工作，本文透過比較憲法理論與中華民國過去制憲的經驗，來探討如果臺灣未來要制憲應採取什麼途徑，前者可以避免閉門造車，後者則可以避免重蹈覆轍。詳言之，由於制憲在全世界越來越頻繁，實務上累積了相當多的案例，因此透過比較憲法理論，我們可以借鏡世界各國如何開啟制憲工程，他們為什麼採取特定的途徑而揚棄其他選項，是各種選項本身的優劣還是各國脈絡的差異所導致？採取這種方法的優點在於他山之石可以攻錯，避免研究者或主政者個人的偏見與局限。然而，比較憲法理論並沒有提供一個可以普遍適用的制憲模板，相反地，比較憲法理論告訴我們，沒有一套憲法設計理論可以滿足不同國家的制憲需求。採取比較憲法這種途徑，必須注意各國制憲工程都是在特定的時間與空間下所進行，換句話說，不能夠忽略本土的脈絡，這在一般的比較法移植是如此，對於憲法這種高度鑲嵌於一國政治、歷史、文化之中的基本法，更是如此。隨著各國歷史背景、政府體制、社會文化，甚至制憲當時的國際情勢有所不同，在憲政制度設計上，橘逾淮為枳是常發生的事情。高度的民眾參與，在瑞士可能象徵著國家認同的提升，而在玻利維亞，則可能反映了民粹主義的興起；相同地，宗教自由的入憲，在某些國家可能早已是共識而根本無需多加討論，但在其他國家則可能造成制憲會議的破局。這意味著臺灣未來的制憲者該如何制憲，相當程度上仍取決於過去的歷史經驗以及未來的政治局勢與社會共識。

面對臺灣制憲的最大阻礙，也就是中國的反對與威脅，憲法理論和制憲經驗實際上能提供的協助很小，從比較憲法的經驗來看，一個可能的做法是透過修憲程序來實質上制憲，這是部分第三波民

主轉型國家所採取的模式。在臺灣的脈絡下，由於形式上這仍然是修改既有憲法而非制定全新的憲法，再加上臺灣已經多次修憲，因此可能引起的國際阻力會比較小。當然，這種刻意模糊修憲與制憲的做法，在臺灣的脈絡下是否可行，仍不確定，而且如此一來可能會失去透過制憲來表彰人民自決的意義，進而使部分人反對這種作法，因此究竟是否應採取這種方式，可能還必須具體地看所修改內容，是否包含國名、國家疆域、憲法前言等涉及國家想像與主權的關鍵內容來決定。

在實際論點上，本文主張應揚棄過去對於制憲權的想像，認為制憲就必然不受任何規範，因此建議臺灣應該討論制憲權的行使主體、制憲委員會的組成、門檻、批准的門檻……等相關細節。至於制憲程序究竟要採取沿用目前修憲程序還是要另以備忘錄處理，本文則認為均無不可，前者失之僵化，但確保新憲的發起具有足夠高的共識，後者比較彈性，但可能為政客所濫用。

更重要的是，本文所描繪的制憲過程，強調程序面向而非實質內容。這種側重程序面的規範意涵在於，與其說有一個先驗的「我們人民」制定一部憲法，不如說一部新憲法重新創造了一個「我們人民」¹⁸³，這正是憲法所具有的轉化（transformation）功能。換句話說，與其說有一群名為「臺灣人」的人民，想要制定一部屬於臺灣人的憲法，更精準的說法可能是臺澎金馬這些島上的人民，想要透過制定一部新憲法來（重新）定義何謂臺灣人。然而，從他國經驗看來，準備制憲時所產生的憲法時刻，有時候是一個危險的時刻，因為本來勉強相安無事的族群，一旦意識到有一方企圖利用憲法鞏固其優勢，將立刻激化衝突，進而造成政局動盪。因此，如何

183 ROBERT A. DAHL, DEMOCRACY AND ITS CRITICS 3-4 (1989); CHAIHARK HAHM & SUNG HO KIM, MAKING WE THE PEOPLE: DEMOCRATIC CONSTITUTIONAL FOUNDING IN POSTWAR JAPAN AND SOUTH KOREA 275-86 (2015).

妥善地透過制憲程序，以接近「永矢咸遵」的境界，就成了重要的課題。考量到臺灣在國家認同上的分裂與國際情勢，更平添制憲的困難，因此如何讓新憲法真正成為凝聚所有這塊土地上人民的象徵，仍有待政府、社會、以及學術界進一步研究與討論。

參考文獻

1. 中文部分

- András Sajó (2008), 論制憲與修憲, 收於: 葉俊榮、張文貞編, 新興民主的憲政改造, 頁71-90, 臺北: 元照。
- 王泰升 (2015), 臺灣法律現代化歷程: 從「內地延長」到「自主繼受」, 臺北: 臺大出版中心。
- 吳玉山 (2006), 政權合法性與憲改模式: 比較台灣與歐洲後共新興民主國家, 收於: 吳重禮、吳玉山編, 憲政改革: 背景、運作與影響, 頁37-39, 臺北: 五南。
- 李仁淼 (2014), 自制憲權之觀點思考我國憲政改革之問題點, 月旦法學教室, 144期, 頁42-53。
- 李建良 (2007), 面對中華民國憲法——思索台灣憲改之路, 收於: 湯德宗、廖福特編, 憲法解釋之理論與實務 (五), 頁55-98, 臺北: 中央研究院法律學研究所籌備處。
- 李炳南 (1993), 政治協商會議與國共談判, 臺北: 永業。
- 李鴻禧 (1994), 李鴻禧憲法教室, 臺北: 月旦。
- 林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞 (2003), 憲法: 權力分立, 臺北: 學林。
- 林佳和 (2021), 憲法政策不得公投? 從公投法第2條第2項第3款談起, 台灣法學雜誌, 410期, 頁65-84。
- 郎裕憲、陳文俊 (1987), 中華民國選舉史, 臺北: 中央選舉委員會。
- 孫宏雲 (2019), 區域代表或職業代表? ——國民黨對職業代表制的理解和運用, 收於: 深町英夫編, 中國議會百年史: 誰代表誰? 如何代表?, 頁83-102, 臺北: 臺大出版中心。
- 荊知仁 (1984), 中國立憲史, 臺北: 聯經。

- 財團法人張榮發基金會國家政策研究資料中心編（1990），共識：中華民國憲法改革案，臺北：財團法人張榮發基金會國家政策研究資料中心。
- 國民大會秘書處編（1946），國民大會實錄，南京：國民大會秘書處。
- 國是會議實錄編輯小組編（1990），國是會議實錄（上輯），臺北：國是會議秘書處。
- 張文貞（2006），憲政改造的方式與程序，收於：行政院研究發展考核委員會編，憲改方向盤，頁16-54，臺北：五南。
- 張嘉尹（2008），憲政改造的途徑選擇——以台灣憲法變遷為脈絡的思考，收於：葉俊榮、張文貞編，新興民主的憲政改造，頁91-124，臺北：元照。
- 許宗力（2000），兩岸關係的法律定位——臺灣的角度出發，收於：黃昭元編，兩國論與台灣國家定位，頁147-157，臺北：學林。
- 許慶雄（2005），中華民國與臺灣之地位——依國際法法理評析，律師雜誌，314期，頁14-25。
- 陳春生（2005），台灣的國家定位，律師雜誌，314期，頁26-48。
- 陳昭如（2012），改寫男人的憲法：從平等條款、婦女憲章到釋憲運動的婦運憲法動員，政治科學論叢，52期，頁43-88。
- 陳英鈴（2019），十案公投綁大選——從比較法省思民主與法治的挑戰，台灣法學雜誌，380期，頁21-42。
- （2021），公投法與政治，臺北：元照。
- 陳荔彤（2005），臺灣在國際上的地位分析，律師雜誌，314期，頁49-61。
- 陳慈陽（2006），制憲與修憲之區分及憲改之必要性，新世紀智庫論壇，35期，頁59-64。
- 曾建元（2014），臺灣制憲運動的回顧與展望——以民主進步黨為中心，法制史研究，25期，頁131-161。

- (2019), 台灣制憲與中國制憲——啟蒙與歷史的辯證, 台灣國際研究季刊, 15卷3期, 頁141-169。
- 黃昭元 (2000), 兩國論的憲法分析——憲法解釋的挑戰與突破, 收於: 黃昭元編, 兩國論與台灣國家定位, 頁3-37, 臺北: 學林。
- 楊家駱 (1973), 大陸淪陷前之中華民國: 民國卅七年份中華年鑑, 第二卷, 臺北: 鼎文。
- 葉俊榮 (2008), 週期修憲的程序理性, 收於: 葉俊榮、張文貞編, 新興民主的憲政改造, 頁11-34, 臺北: 元照。
- 葉俊榮、張文貞 (2006), 路徑相依或制度選擇? 論民主轉型與憲法變遷的模式, 問題與研究, 45卷6期, 頁1-31。
- 賈文宇 (2021), 公民投票的憲法功能與民主意義, 台灣法學雜誌, 410期, 頁53-63。
- 雷震 (2010), 中華民國制憲史——政治協商會議憲法草案, 新北市: 稻鄉。
- 蔡宗珍 (1997), 從制憲力之法理論憲法之制訂與修改, 法政學報, 7期, 頁109-133。
- 蘇永欽 (2008), 尋找共和國, 臺北: 元照。
- 蘇彥圖 (2017), 憲政民主的死人之手問題——憲法規範權威的初步反省, 收於: 李建良編, 憲法解釋之理論與實務 (九), 頁135-199, 臺北: 中央研究院法律學研究所。

2. 外文部分

- Ackerman, Bruce. 1992. *The Future of Liberal Revolution*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Al-Ali, Zaid. 2011. Constitutional Drafting and External Influence. Pp. 77-95 in *Comparative Constitutional Law*, edited by Tom Ginsburg and Rosalind Dixon. Northampton, MA: Edward Elgar.

- Albert, Richard. 2014. Constitutional Amendment by Constitutional Desuetude. *American Journal of Comparative Law* 62:641-686.
- . 2019. *Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions*. New York, NY: Oxford University Press.
- Albert, Richard, Xenophon Contiades, and Alkmene Fotiadou. 2019. Introduction: Imposition in Making and Changing Constitutions. Pp. 1-12 in *The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions*, edited by Richard Albert, Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou. Abingdon: Routledge.
- Amar, Akhil Reed. 1994. The Consent of the Governed: Constitutional Amendment outside Article V. *Columbia Law Review* 94:457-508.
- Arato, Andrew. 2009. *Constitution Making Under Occupation: The Politics of Imposed Revolution in Iraq*. New York, NY: Columbia University Press.
- . 2016. *Post Sovereign Constitution Making: Learning and Legitimacy*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2017. *The Adventures of the Constituent Power: Beyond Revolutions?*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Bannon, Alicia L. 2007. Designing a Constitution-Drafting Process: Lessons from Kenya. *Yale Law Journal* 116:1824-1872.
- Beramendi, Virginia, Andrew Ellis, Bruno Kaufman, Miriam Kornblith, Larry LeDuc, Paddy McGuire, Theo Schiller, and Pelle Svensson. 2008. *Direct Democracy: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Blount, Justin. 2011. Participation in Constitutional Design. Pp. 38-56 in *Comparative Constitutional Law*, edited by Tom Ginsburg and Rosalind Dixon. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Blount, Justin, Zachary Elkins, and Tom Ginsburg. 2012. Does the Process of Constitution-Making Matter?. Pp. 31-66 in *Comparative*

- Constitutional Design*, edited by Tom Ginsburg. New York, NY: Cambridge University Press.
- Braune, Andreas. 2020. Authoritative Constitution-Making in the Name of Democracy?. Pp. 323-344 in *Constitutionalism under Extreme Conditions: Law, Emergency, Exception*, edited by Richard Albert and Yaniv Roznai. Cham: Springer.
- Carey, John M. 2009. Does It Matter How a Constitution Is Created?. Pp. 155-177 in *Is Democracy Exportable?*, edited by Zoltan Barany and Robert G. Moser. New York, NY: Cambridge University Press.
- Colón-Ríos, Joel. 2012. *Weak Constitutionalism: Democratic Legitimacy and the Question of Constituent Power*. Abingdon: Routledge.
- . 2020. *Constituent Power and the Law*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2020. Constitution Making through Law. Pp. 33-52 in *Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives*, edited by Gabriel L. Negretto. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crawford, James. 2006. *The Creation of States in International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dahl, Robert A. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dixon, Rosalind. 2015. Constitutional Drafting and Distrust. *International Journal of Constitutional Law* 13:819-846.
- . 2019. Constitutional Design Deferred. Pp. 165-185 in *Comparative Constitution Making*, edited by David Landau and Hanna Lerner. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Dixon, Rosalind, and Tom Ginsburg. 2011. Deciding not to Decide: Deferral in Constitutional Design. *International Journal of Constitutional Law* 9:636-672.

- Doyle, Oran. 2018. The Silent Constitution of Territory. *International Journal of Constitutional Law* 16:887-903.
- Eisenstadt, Todd A., A. Carl LeVan, and Tofigh Maboudi. 2015. When Talk Trumps Text: The Democratizing Effects of Deliberation during Constitution-Making, 1974-2011. *American Political Science Review* 109:592-612.
- Elkins, Zachary, Tom Ginsburg and James Melton. 2008. Baghdad, Tokyo, Kabul ...: Constitution Making in Occupied States. *William & Mary Law Review* 49:1139-1178.
- . 2009. *The Endurance of National Constitutions*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Elster, Jon. 1979. *Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality*. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 1995. Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process. *Duke Law Journal* 45:364-396.
- . 2000. *Ulysses Unbound*. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2006. Legislatures as Constituent Assemblies. Pp. 181-197 in *The Least Examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State*, edited by Richard W. Bauman and Tsvi Kahana. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2012. Clearing and Strengthening the Channels of Constitution Making. Pp. 15-30 in *Comparative Constitutional Design*, edited by Tom Ginsburg. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2012. The Optimal Design of a Constituent Assembly. Pp. 148-172 in *Collective Wisdom: Principles and Mechanisms*, edited by Hélène Landemore and Jon Elster. New York, NY: Cambridge University Press.

- , ed. 2015. *Secrecy and Publicity in Votes and Debates*. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2018. The Political Psychology of Constitution Making. Pp. 207-246 in *Constituent Assemblies*, edited by Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch. New York, NY: Cambridge University Press.
- Feldman, Noah. 2005. Imposed Constitutionalism. *Connecticut Law Review* 37:857-889.
- Gargarella, Roberto. 2018. Constitution Making in the Context of Plural Societies: The “Accumulation Strategy”. Pp. 13-30 in *Constituent Assemblies*, edited by Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch. New York, NY: Cambridge University Press.
- Ghai, Yash, and Guido Galli. 2006. Constitution-building Processes and Democratization: Lessons Learned. Pp. 232-249 in *Democracy, Conflict and Human Security: Further Readings*, edited by International IDEA. Stockholm: International IDEA.
- Ginsburg, Tom. 2010. Constitutional Specificity, Unwritten Understandings and Constitutional Agreement. Pp. 69-94 in *Constitutional Topography: Values and Constitutions*, edited by András Sajó and Renáta Uitz. Hague: Eleven International Publishing.
- Ginsburg, Tom, and Aziz Z. Huq. 2020. Introduction: From Parchment to Practice. Pp. 1-28 in *From Parchment to Practice: Implementing New Constitutions*, edited by Tom Ginsburg and Aziz Z. Huq. New York, NY: Cambridge University Press.
- Ginsburg, Tom, and James Melton. 2015. Does the Constitutional Amendment Rule Matter at All? Amendment Cultures and the Challenges of Measuring Amendment Difficulty. *International Journal of Constitutional Law* 13:686-713.

- Gunther, Richard. 1985. Constitutional Change in Contemporary Spain. Pp. 42-70 in *The Politics of Constitutional Change in Industrial Nations: Redesigning the State*, edited by Keith G. Banting and Richard Simeon. London: Palgrave Macmillan.
- Gylfason, Thorvaldur. 2018. Chain of Legitimacy: Constitution Making in Iceland. Pp. 161-185 in *Constituent Assemblies*, edited by Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch. New York, NY: Cambridge University Press.
- Hahm, Chaihark, and Sung Ho Kim. 2015. *Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Hasebe, Yasuo. 2009. On the Dispensability of the Concept of Constituent Power. *Indian Journal of Constitutional Law* 3:39-51.
- Horowitz, Donald L. 2002. Constitutional Design: Proposals versus Processes. Pp. 15-36 in *The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy*, edited by Andrew Reynolds. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2021. *Constitutional Processes and Democratic Commitment*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Irving, Helen. 2011. Drafting, Design and Gender. Pp. 19-37 in *Comparative Constitutional Law*, edited by Tom Ginsburg and Rosalind Dixon. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Jacobsohn, Gary Jeffrey, and Yaniv Roznai. 2020. *Constitutional Revolution*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Klarman, Michael J. 2016. *The Framers' Coup: The Making of the United States Constitution*. New York, NY: Oxford University Press.
- Klein, Claude, and András Sajó. 2012. Constitution-Making: Process and Substance. Pp. 419-441 in *The Oxford Handbook of*

- Comparative Constitutional Law*, edited by Michel Rosenfeld and András Sajó. Oxford: Oxford University Press.
- Kumarasingham, H., ed. 2016. *Constitution-making in Asia: Decolonisation and State-Building in the Aftermath of the British Empire*. Abingdon: Routledge.
- Landau, David. 2012. The Importance of Constitution-Making. *Denver University Law Review* 89:611-633.
- . 2013. Abusive Constitutionalism. *U.C. Davis Law Review* 47:189-260.
- . 2013. Constitution-Making Gone Wrong. *Alabama Law Review* 64:923-980.
- . 2019. Constituent Power and Constitution Making in Latin America. Pp. 567-588 in *Comparative Constitution Making*, edited by David Landau and Hanna Lerner. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- . 2020. Courts and Constitution Making in Democratic Regimes: A Contextual Approach. Pp. 78-100 in *Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives*, edited by Gabriel L. Negretto. Cambridge: Cambridge University Press.
- Landau, David, and Rosalind Dixon. 2015. Constraining Constitutional Change. *Wake Forest Law Review* 50:859-890.
- Landemore, Hélène. 2013. *Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lerner, Hanna. 2011. *Making Constitutions in Deeply Divided Societies*. New York, NY: Cambridge University Press.

- Levinson, Sanford, ed. 1995. *Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . 2006. *Our Undemocratic Constitution: Where the Constitution Goes Wrong (And How We the People Can Correct It)*. New York, NY: Oxford University Press.
- Lijphart, Arend. 2012. *Patterns of Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Lombardi, Clark B., and Shamshad Pasarlay. 2022. Constitution-Making for Divided Societies: Afghanistan. Pp. 89-112 in *Constitutionalism in Context*, edited by David S. Law. New York, NY: Cambridge University Press.
- Lorenz, Astrid. 2005. How to Measure Constitutional Rigidity. *Journal of Theoretical Politics* 17:339-361.
- Loughlin, Martin. 2003. *The Idea of Public Law*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2022. *Against Constitutionalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lutz, Donald S. 2006. *Principles of Constitutional Design*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malagodi, Mara. 2018. Constituent Assembly Failure in Pakistan and Nepal. Pp. 79-108 in *Constituent Assemblies*, edited by Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2018. The Rejection of Constitutional Incrementalism in Nepal's Federalisation. *Federal Law Review* 46:521-540.
- Meuwese, Anne. 2013. Popular Constitution-Making: The Case of Iceland. Pp. 469-496 in *Social and Political Foundations of*

- Constitutions*, edited by Denis J. Galligan and Mila Versteeg. New York, NY: Cambridge University Press.
- Michel, Stephan, and Ignacio N. Cofone. 2017. Majority Rules in Constitutional Referendums. *KYKLOS* 70:402-424.
- Moehler, Devra C. 2008. *Distrusting Democrats: Outcomes of Participatory Constitution Making*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Mueller, Dennis C. 2001. On Writing a Constitution. Pp. 9-32 in *Rules and Reason: Perspectives on Constitutional Political Economy*, edited by Ram Mudambi, Pietro Navarra and Giuseppe Sobbrío. New York, NY: Cambridge University Press.
- Murphy, Walter F. 2009. Designing a Constitution: Of Architects and Builders. *Texas Law Review* 87:1303-1338.
- Negretto, Gabriel L. 2013. *Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2018. Constituent Assemblies in Democratic Regimes: The Problem of a Legally Limited Convention. Pp. 31-56 in *Perspectives on Constituent Assemblies*, edited by Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2020. New Constitutions in Democratic Regimes. Pp. 1-30 in *Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives*, edited by Gabriel L. Negretto. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2020. Replacing Constitutions in Democratic Regimes: Elite Cooperation and Citizen Participation. Pp. 101-128 in *Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and*

- Comparative Perspectives*, edited by Gabriel L. Negretto. Cambridge: Cambridge University Press.
- Negri, Antonio. 1999 (1992). *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, translated by Maurizia Boscagli. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Partlett, William. 2012. The Dangers of Popular Constitution-Making. *Brooklyn Journal of International Law* 38:193-238.
- . 2016. The Elite Threat to Constitutional Transitions. *Virginia Journal of International Law* 56:407-458.
- . 2020. Expanding Revision Clauses in Democratic Constitutions. Pp. 53-77 in *Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives*, edited by Gabriel L. Negretto. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Rosenfeld, Michel. 2009. *The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community*. Abingdon: Routledge.
- Rosenn, Keith S. 1990. Brazil's New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for a Transitional Society. *American Journal of Comparative Law* 38:773-802.
- Roznai, Yaniv. 2016. *Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2018. "We the People", "Oui, the People" and the Collective Body: Perceptions of Constituent Power. Pp. 295-316 in *Comparative Constitutional Theory*, edited by Gary Jacobsohn and Miguel Schor. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- . 2022. Constitutional Transformation: Hungary. Pp. 136-156 in *Constitutionalism in Context*, edited by David S. Law. New York, NY: Cambridge University Press.
- Schneider, Edward. 2006. *Crafting Constitutional Democracies: The Politics of Institutional Design*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Sripati, Vijayashri. 2020. *Constitution-Making under UN Auspices*. Oxford: Oxford University Press.
- Strauss, David A. 2001. The Irrelevance of Constitutional Amendments. *Harvard Law Review* 114:1457-1505.
- Tierney, Stephen. 2012. *Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Tomoszek, Maxim. 2013. The Czech Republic. Pp. 41-68 in *How Constitutions Change: A Comparative Study*, edited by Dawn Oliver and Carlo Fusaro. Portland, OR: Hart Publishing.
- Tully, James. 2007. The Imperialism of Modern Constitutional Democracy, Pp. 315-338 in *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*, edited by Martin Loughlin and Neil Walker. Oxford: Oxford University Press.
- Tushnet, Mark. 1999. The Possibilities of Comparative Constitutional Law. *Yale Law Journal* 108:1225-1309.
- Vermeule, Adrian. 2007. *Mechanisms of Democracy: Institutional Design Writ Small*. New York, NY: Oxford University Press.
- Voigt, Stefan. 2004. The Consequences of Popular Participation in Constitutional Choice—Towards a Comparative Analysis. Pp. 199-229 in *Deliberation and Decision: Economics, Constitutional Theory and Deliberative Democracy*, edited by Anne van Aaken, Christian List and Christoph Luetge. Burlington, VT: Ashgate.

- Wallis, Joanne. 2014. *Constitution Making during State Building*. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2019. Constitution Making and State Building. Pp. 278-301 in *Comparative Constitution Making*, edited by David Landau and Hanna Lerner. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Weingast, Barry R. 1997. The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law. *American Political Science Review* 91:245-263.
- Widner, Jennifer. 2008. Constitution Writing in Post-Conflict Settings: An Overview. *William & Mary Law Review* 49:1513-1541.
- Williams, David C. 2009. Constitutionalism before Constitutions: Burma's Struggle to Build a New Order. *Texas Law Review* 87:1657-1694.
- Yam, Kai Chi, Joshua C. Jackson, Christopher M. Barnes, Jenson Lau, Xin Qin, and Hin Yeung Lee. 2020. The Rise of COVID-19 Cases Is Associated with Support for World Leaders. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117:25429-25433.
- Yeh, Jiunn-Rong. 2016. *The Constitution of Taiwan: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.

Memorandum to Taiwan's Constitution Makers:

The Procedural Dimension

*Chien-Chih Lin**

Abstract

Enacted in China in 1947, the current supreme law in Taiwan, the Constitution of the Republic of China, albeit workable, is ill-suited for Taiwanese people. In this sense, Taiwan will eventually need to enact a new constitution—a task that is fraught with difficulties, as constitution-making is a highly risky and costly project that may easily spawn domestic chaos and international disturbance. The task is made all the more difficult because the Taiwanese people have not discussed in sufficient depth the various critical aspects of constitution-making. Taken together, these difficulties may lead to tragic outcomes in Taiwan. Weaving together theories of constitution-making and the history behind the drafting of the ROC Constitution, this paper suggests that Taiwan should engage in a nation-wide discussion about the procedural issues involved in enacting a new constitution. Such a discussion may prevent populist constitution-making in times of emergency and create a political veil of ignorance which may improve the quality of the new constitution.

KEYWORDS: constitution-making, constitutional change, imposed constitution, referendum, civic participation.

* Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica; Associate Professor, Graduate Institute of National Development, National Taiwan University.